

SINTAKSA PRAVA – Riccardo Guastini

prijevod: Luka Burazin

Uvod

Dva pristupa filozofiji (pozitivnog) prava

1. Pravo i pravna znanost

- **Pravo** – skup onih normativnih akata koje su uobičajeno naziva „**zakonima**“
- **Jurisprudencija** – u uobičajenoj uporabi označava skup sudskih odluka
tu koristimo u izvornom smislu ***juris prudentia*** ili ***sapientia juris*** -pravno znanje, znanost o pravu
Disciplina koju prakticiraju akademski pravnici (profesori prava) i suci

2 različita načina shvaćanja i prakticiranja filozofije prava

1. filozofija (pozitivnog) prava kao meta-pravna znanost (meta-jurisprudencija)
2. filozofija (pozitivnog) prava kao pojmovni laboratorij (konstruiranje pojmova)

2. Oruđa filozofije prava

- **DEFINICIJA** - iskaz pomoću kojega se određuje značenje neke riječi ili izraza (sintagme)
- standardni oblik definicije jest - '**x**' **znači** '**y**' – npr. Demokracija' znači vladavina naroda
→ **x** = definiendum (sintagma koja se definira) , **y** = definiens (izraz kojim ga se definira)

2 su osnovne vrste definicije

1. **informativne definicije** – mogu biti istinite ili neistinite
 - njima se opisuje na koji se način netko stvarno koristi definirani izraz
2. **stipulativne definicije** – nisu ni istinite niti neistine
 - 1. predlažu uporabe već postojeće riječi na nov način, na način precizniji od opće uporabe (redefiniraju) ili daju značenje novonastaloj riječi ili sintagmi

Razlikovanje empirijskih i analitički iskaza

EMPIRIJSKI iskaz – (npr. snijeg je bijel – istinit, snijeg je plav – neistinit)

- odnosi se na činjenice
- može biti istinit ili neistinit
- koji je nužno istinit ili neistinit s obzirom na svoj odnos prema svijetu

ANALITIČKI iskaz

- ne odnosi se na činjenice
- nužno je istinit ili neistinit
- nužno je istinit ili neistinit ne s obzirom na odnos prema svijetu, prema činjenicama, nego isključivo s obzirom na:
 1. svoju logičku strukturu (npr. Petar je ili živ ili nije živ, Pavao je živ i mrtav)
 2. značenje (Nijedan neženja nije oženjen, Neženje su neoženjeni)

analitički iskazi su:

1. tautološki - nužno istiniti (neženja je neoženjen muškarac)
2. samoproturječni - nužno neistiniti (Pavao je živ i mrtav)

Razlikovanje jezika i metajezika

1. riječima se redovito govori o „stvarima“ – „Mačka ima 4 noge“ – govori se o mačkama
 - **METAJEZIK**- jezik kojim se izražavano
2. ali riječima se govori i o drugim riječima – „Riječ mačka ima 5 slova“ govori se o riječi „mačka“
 - **JEZIK-PREDMET** - jezik o kojem govorimo
 - „metajezik“ je iznad „jezika-predmeta“

Razlikovanje opisujućih i propisujućih iskaza

- **OPISUJUĆI iskazi** – jezik znanosti, mogu biti istiniti ili neistiniti izražavaju i prenose informacije o svijetu (Snijeg je bijel. Snijeg je plav)
- **PROPISUJUĆI iskazi** – jezik prava (i morala), ne mogu biti ni istiniti ni neistiniti usmjeren na mijenjanje ponašanja ljudi (Ne ubij. Zabranjeno pušenje)
- razlikovanje 2 iskaza ovisi o sporovima: spor o činjenicama (razrješiv) i spor o normama (neraz)

Razlikovanje motiva i razloga

- **MOTIVI** - duševna, psihička stanja; pobude, osjećaji, emocije potiču na imanje nekog vjerovanja, podupiranje neke tvrdnje ili donošenje neke odluke
- **RAZLOZI** - jezični iskazi koji se javno iznose radi podupiranja ili opravdavanja neke tvrdnje ili odluke; tj. **PRETPOSTAVKE RASUĐIVANJA**
- **Rasuđivanje** - slijed iskaza unutar kojeg barem jedan iskaz služi kao zaključak, a preostali iskazi kao razlozi kojima se podupire taj zaključak

3. Filozofija prava kao filozofija pravne znanosti

- pravo, pravna znanost i filozofija prava se nalaze na trima različitim jezičnim razinama
- **PRAVO** – je jezik, diskurs normatvorca, zakonodavca – tj. skup normativnih tekstova i dokum.
- **PRAVNA ZNANOST** – je metajezik – sastoji se od analize jezika prava
- **FILOZOFIJA PRAVA** – je meta-metajezik – jezik 3. stupnja, jezik-predmet pravne znanosti

4. Filozofija prava kao pojmovni laboratorij

Drugi odnos između prava, pravne znanosti i filozofije prava

- **Pravna znanost** je rad, odgovara na pitanja - Što se pravom određuje, koji je normativni sadržaj?
- **Filozofija prava** je pojmovni pothvat, odgovara na probleme formuliranja i organiziranja znanja sastoji se od oblikovanja pojmova prikladnih za opisivanje prava nuđenje različitih rješenja nekog problema utječe na način opisivanja prava

Prvi dio

JEZIK, NORME, PRAVO

I. UPORABE RIJEČI PRAVO

- nema jedno, nedvosmisleno značenje – obično se upotrebljuje u najmanje 4 različita konteksta

1. Pravo u objektivnom smislu

- **PRAVO** - eng. "law" - skup normi ili pravila određene vrste usmjerenih na ponašanja ljudi
 - poseban skup pravila ili normi kojima se uređuje:
 - 1.) Suzbijanje ponašanja ocijenjenih društveno opasnim
 - 2.) Raspodjela dobara i usluge pojedincima i skupinama
 - 3.) Ustanovljivanje i dodjeljivanje javne vlasti
- npr. „Talijansko pravo zabranjuje ubojstvo“, „Međunarodno pravo zabranjuje rat“...
- da se izbjegne višeznačnost, upotrebljava se još i – objektivno pravo, pravni poredak/sustav
- **Pravno** – znanost koja proučava objektivno pravo, ne pripada pravu nego za predmet ima pravo

2. Unutarnja razdioba objektivnog prava

- u izričajima poput - građansko pravo, ustavno pravo, trgovačko pravo – riječ **pravo** također označava skup normi, ali ukupnost samo jednog dijela (jednog podskupa) toga skupa
- jedno je kemijska olovka, drugo kemijska znanost, isto tako jedno je pravo, drugo pravna znanost
- **Pravna znanost** - nije pravna u istom smislu kao i pravne norme, nije dio prava, ali se odnosi na nju

3. Pravo u subjektivnom smislu

- u izričajima poput – Imam pravo reći što mislim, Građani se imaju pravo udruživati
- eng. "wright"; označava nekom subjektu pripisanu mogućnost, dopuštenje ili vlast
- upotrebljava se još i izraz „subjektivno pravo“ (pravo u subjektivnom smislu)
- „**subjektivno pravo**“ je umjetna kakvoća, ljudi imaju ako i kada su im pripisane
- ljudi subjektivna prava imaju na osnovi objektivnog prava

4. Pravni automatizam

- npr. „U slučaju odsutnosti ili spriječenosti rektora, sukladno pravu zamjenjuje ga prorektor.“
- riječ **pravu** nema samostalno značenje, stječe ga jedino s prilogom „sukladno“
- „sukladno pravu“ ovdje znači **automatski** = to jest bez posredovanja nekoga ili nečega
- **automatizam** nije određen prirodom stvari, on ovisi o objektivnom pravu

II. PRAVU I MORALU

1. Moral

1. **Društveni** ili **pozitivni** - skup vrijednosti, shvaćanja dobrog, osjećaja pravednosti i pravila ponašanja u nekom društvenom okružju
2. **Poseban, kritički** ili **idealni** - skup vrijednosti, shvaćanja dobrog, osjećaja pravednosti i pravila ponašanja poduprtih nekom moralnom doktrinom (npr. doktrina liberalnog morala)

2. Moral v. pravo

- Pravo i moral skupovi su pravila ili normi koji za predmet imaju ponašanje ljudi
na prvi pogled 2 razlikovna obilježja
- 1. **Pravni poredci** tipično uređuju uporabu sile, fizičke prisile - **pravo** je tehnika postizanja željenog ponašanja putem prijetnje prisilnim lišavanjem vlasništva / slobode / života
- 2. **Pravni poredci** imaju jedinstvenu strukturu, mnogo složeniju od strukture moralnih poredaka uključuju norme koje uređuju tko i kako može stvarati nove norme ili primjenjivati postojeće
Pravo uređuje i svoje vlastito stvaranje i primjenu
- pravo i moral se razlikuju i po sadržaju i po strukturi – nisu potpuno nepovezani

3. Pojemni odnosi

- svaki odnos između dvaju ili više pojmova - jednog od njih se ne može def bez drugoga
- **Definicija** – iskaz kojim se uspostavlja odnos između pojmova

Nužni i kontingentni odnosi:

- a) Odnos je **NUŽAN** kada ne može ne postojati - pojmovni odnosi su nužni
odnos između prava i normi je nužan; ako je nešto pravo onda to ne može ne biti skup normi)
- b) **KONTINGENTAN** kada može postojati i ne postojati - činjenični odnosi su kontingentni
cenzura i sloboda tiska – u nekim poredcima tisk slobodan, dok u drugim nije (podvrgnut cenzuri)

postoji li između prava i morala pojmovni ili nužni odnosi? odgovor 2 načina

1. **Pravni naturalizam (JUSNATURALIZAM)** odgovara potvrdno
pravo skup dobrih i pravednih normi; ako neki skup normi nije dobar i pravedan onda nije pravo
2. **Pravni pozitivizam (JUSPOZITIVIZAM)** → kaže da pravo nije nužno dobro ili pravedno
pravo se nužno ne podudara s društvenim moralom; ima pravednih i nepravednih pravnih normi

4. Činjenični odnosi

Pravo je pod utjecajem morala u dva smisla:

1. Sadržaj prava ovisi o kritičkom moralu normotvorca (ustavotvoraca, zakonodavaca itd)
normotvorci teže stvaranju pravnih normi koje odražavaju njihove moralne nazore i pol usmjerenja
2. Sadržaj prava barem djelomično odražava društveni moral tj. općeprihvaćene moralne nazore
s druge strane pravo pak može utjecati na moral društva, na promjenu društ. moralnih uvjerenja

III. JEZIK PRAVA

1. Pravo kao diskurs

- **diskurs** je slijed iskaza; **iskaz** je slijed riječi koji ima sintaktički oblik i smisao
 - iskazi od kojih se sastoji pravo iskazi su normativnog ili propisujućeg ili direktivnog jezika
 - razlika između opisujućeg i propisujućeg iskaza - **3 gledišta:pragmatičko, sintaktičko i semantičko**
1. **PRAGMATIKA** propisujućeg jezika
 - gledišta djelovanja koje se izvodi izgovaranjem iskaza – **2 vrste ljudskih akata**
 - 1. **Nejezični akti** - oni koji se ne mogu izvesti riječima (reći šecem nije šetati)
 - 2. **Jezični akti** - oni koji se izvode pomoću jezika,izvršavaju riječima (kladim se da..obećajem da...)
 - određeni akti mogu biti i opisujući (radi izvođenja akta opisivanja) i propisujući

2. SINTAKSA propisujućeg jezika

- **opisujući** iskazi imaju *indikativni* glagolski oblik ("Ubojice su kažnjeni!")
- **propisujući** iskazi imaju *imperativni* glagolski oblik ("Kazni ubojice!") ili *deontički* glagolski oblik ("Ubojice treba kazniti")
- sintaktički oblik nekog iskaza samo je znak ili indicija, ali ne i konačni dokaz njegove opisujuće ili propisujuće naravi

3. SEMANTIKA propisujućeg jezika

- Opisujući se iskazi pokušavaju prilagoditi svijetu, dok propisujući nastoje da se svijet prilagodi njima
- iskazi **opisujućeg** jezika (sudovi) imaju istinosnu vrijednost, iskazi **propisujućeg** jezika (propisi, zapovijedi ...) nemaju istinosnu vrijednost → moguće im se jedino pokoriti ili ih prekršiti

2. *Pravo kao propisujući diskurs ako su:*

1. barem neki od iskazi koji ga čine propisujući u užem (razred propisujućih iskaza u užem smislu)
2. Preostali iskazi funkcionalno ovisni o propisima (razred svih preostalih iskaza)

IV. **NORME**

1. *Uobičajena uporaba izraza „pravna norma“*

- 2 bitna podrazreda pravnih normi:
1. **Norma u užem smislu:**
 1. Propis (zapovijed propustiti ili učiniti)
 2. S pogodbenom strukturom
 3. Čiji je sadržaj opći i apstraktan
 2. **Norma u širem smislu** – govorit će se u idućem poglavlju

2. *Norma kao propis*

- **norma** je dakle propis, zapovijed → **propis** može označavati 3 različite stvari: **akt, iskaz i značenje**
1. **Propis kao akt** - akt propisivanja; jezični akt (čin) namijenjen usmjeravanju ljudskog ponašanja, upravljanju njime, utjecanju na njega i njegovu mijenjanju
 2. **Propis kao iskaz** - propisujući iskaz je onaj koji
 - a) Se odnosi na ponašanje (radnju i propuštanje)
 - b) Koji to ponašanje kvalificira kao: **obvezno** (obvezna radnja = naziva se zapovijed, obvezno propuštanje = prohibicija ili zabrana) ili **trebano**; pokoravanje zapovijedi = naziva se izvršavanje, pokoravanje zabrani = pridržavanje
 3. **Propis kao značenje** - sadržaj akta propisivanja
 - **PROPISI** – su podložni pokoravanju ili kršenju – preostalim iskazima diskursa ne upravlja ponašanje adresata – to su norme u općenitom smislu, nisu podložni ni pokoravanju ni kršenju
 - **normi** nema bez akata propisivanja, niti normi bez propisujućih iskaza

3. Norma kao propis s pogodbenom strukturom

- navodi se što treba učiniti ili propustiti, ako se ostvare određene okolnosti
- **pravne norme** nisu kategorički (bezuvjetni) kao npr. „Zabranjeno je ubiti“ nego su **pogodbeni** ili **hipotetički** „Ako netko prouzroči smrt druge osobe, onda ga treba kazniti“

2 sastavna elementa pogodbenog ili hipotetičkog iskaza

1. **ANTECEDENT** (prednjak) ili protaza - dio iskaza u kojemu se određuje uvjet ("Ako...") naziva se činjenično stanje - **predmet je utvrđivanja**, daje odgovor na pitanje 'Što je uređeno?'
2. **KONSEKVENT** (posljedak) ili apodaza - dio iskaza u kojemu se utvrđuje posljedica ("...onda...")
način uređivanja, daje odgovor na pitanje 'Kako je uređeno?'

4. Norma kao opći propis

- **Norma** je opći propis, odnosno „pravilo ponašanja“
- pojam općosti se može razumjeti u opreci s pojmom općenitosti, uzimajući u obzir činjenična stanja
- **pojedinacnim** se naziva propis koji za predmet ima pojedinačno činjenično stanje, tj. **konkretno** činjenično stanje npr. Ubojstvo Petra od strane Pavla, Ugovor između Marka i Luke
- **općim** se naziva propis koji za predmet ima razred činjeničnih stanja, tj. **apstraktno** činjenično stanje npr. sva ubojstva koja bilo tko počini protiv bilo koga

5. Norma kao apstraktni propis

Dva pojma apstraktnosti (apstrahiranje=neovisnost)

1. Propis je apstraktan kada je opći (apstraktno = opće)
 2. Propis je apstraktan kada *nije unatražnodjelujući* (retroaktivan)
propis je unatražnodjelujući kada pravnu posljedicu povezuje s činjenicom koja je nastala prije dotičnog propisa- npr. dohodci ostvareni u protekloj godini)
- ima smisla reći da su norme opći i apstraktni propisi; norma je neunatražnodjelujući propis

6. Određivanje v. rješavanje

- **odrediti** znači utanačiti pravnu posljedicu općeg i apstraktnog činjeničnog stanja tj. odlučiti **ex ante** u odnosu na razred budućih činjeničnih stanja, čije se nastupanje zbog toga pretpostavlja
- **riješiti** znači utanačiti pravnu posljedicu jednog ili više konkretnih činjeničnih stanja, tj. odlučiti **ex post facto** u odnosu na točno određene okolnosti koje su već nastupile

V. VRSTE NORMI

1. Norme u općenitom smislu (ne propisujuće) + 2. Fragmenti normi

- 1.) **NORME O NADLEŽNOSTI** - one kojima se dodjeljuje vlast stvaranja i ukidanja propisa
- 2.) **DOPUŠTAJUĆE NORME** - one kojima se određeno ponašanje kvalificira kao dopušteno, neobavezno ili slobodno; izvršavaju funkciju:
 - a) Ukidanja postojećih propisa ili ograničavanja njihova dosega
 - b) Zabranjivanja podređenom tijelu normativne vlasti da stvara buduće propise

- 3.) **DEFINIRAJUĆE NORME** - one kojima se određuje značenje neke riječi ili sintagme koja se upotrebljuje u formulaciji drugih normi (definicija ugovora)
 - 4.) **TUMAČEĆE NORME** - one kojima se određuje značenje nekog iskaza upotrebljenog u formulaciji neke ranije norme ("Članak x zakona y treba shvatiti u smislu da..") izvršavaju funkciju određivanja sadržaja postojećih propisa
 - 5.) **UPUČUJUĆE NORME** - one kojima se upućuje organe primjene (sudove, javnu upravu) na to koje propise trebaju primijeniti
 - 6.) **NORME O SPOSOBNOSTI DJELOVANJA NORMI** - one kojima se npr. u vremenu ili prostoru ograničavaju pravni učinci drugih normi
 - 7.) **NORME O SUKOBIMA IZMEĐU NORMI** - one kojima se organima ukazuje na to kojim propisima dati prednost u slučaju sukoba između više propisa
 - 8.) **UKIDAJUĆE NORME** - one kojima se ukida sposobnost djelovanja neke već postojeće norme ("Ukida se članak x zakona y")
- sve nepropisjuće norme ili norme u općem smislu izvršavaju neku funkciju u odnosu na propise
 - to su **fragmenti** propisa s kojima se povezuju; tako npr. definirajuća norma je fragment svih propisa u kojima je upotrebljen njome definiran izraz

3. UTEMELJUJUĆE NORME:

- one kojima se nikome ništa ne propisuje - njima se neposredno stvara neki pravni učinak
- DVA TIPRA UTEMELJUJUĆIH NORMI:*

- 1.) Norme koje se ne mogu povezati sa standardnim oblikom pogodbenog iskaza kao npr. definirajuće norme, ukidajuće norme..
- 2.) Norme koje iako imaju pogodbenu strukturu (ako Č onda P), u konsekventu nemaju deontičke izraze (nisu norme o ponašanju); npr. "Osobe s napunjenih 18 godina su punoljetne"

4. Norme i metanorme -2 načina uporabe izraza METANORMA

- 1.) U užem smislu, svaka norma koja za predmet ima druge norme ili druge odredbe nisu norme u užem smislu već fragmenti normi
- 2.) U širem smislu, norme koje za predmet imaju normativne akte

5. Primarne norme i sekundarne norme

- 1.) **PRIMARNE** - norme o ponašanju, tj one kojima se građanima pripisuju ili nameću subjektivni pravni položaji (prava, obveze itd,)
- 2.) **SEKUNDARNE** - metanorme u širem smislu; norme o stvaranju i primjeni prava, tj. one kojima se dodjeljuju vlasti i uređuju njihovo izvršenje

6. Formuliranje norme i neizražene norme

- **FORMULIRANE** - donošene ili proglašene ali u općenitom i netehničkom smislu
- **NEIZRAŽENE** – su naprotiv norme izvedene iz formuliranih normi na temelju argumentacijskih postupaka različite naravi

VI. NORME O PONAŠANJU

1. Deontički načini

- **Normama o ponašanju** nazivaju se sve one norme čije se konsekventom neko ponašanje (činjenice ili propuštanje) kvalificira kao *zabranjeno*, *dopušteno*, *obavezno* i *neobavezno*
- izrazi *zabranjeno*, *dopušteno*, *obavezno* i *neobavezno* nazivaju **deontičkim izrazima** (ili deontičkim modelatima) – jer se svi mogu prevesti izrazom „**dužnost**“ ili „**obveza**“
- **Zapovjedne norme** - njima se kvalificira obvezno ili zabranjeno ponašanje
- **Dopuštajuće norme** - njima se kvalificira dopušteno ili neobvezno ponašanje

2. Značenje deontičkih izraza

za razjašnjenje deontičkih izraza potrebna su **3 zapažanja**:

1. Deontički izrazi su jezična sredstva za kvalificiranje, ne za označavanje ljudskih ponašanja, stavova
 - služe uspostavi normativne veze između subjekta (adresata norme) i ponašanja (predmeta norme)
2. Deontički izrazi se ne mogu definirati nedeontičkim izrazima
 - oni su **interdefinibilni** - mogu se definirati samo jedan pomoću drugoga
3. Jedan od deontičkih izraza uzima se kao primitivni, nedefinirani izraz za definiranje svih ostalih (pomoću negacije)
npr. „Zabranjeno je da...“ znači „Obavezno je da...“
„Dopušteno je da...“ znači „Nije dopušteno da...“
„Neobavezno je da...“ znači „Nije obavezno da...“

3. Logički iskazi između deontičkih izraza

- 1.) Dopušteno i nedopušteno su alternativni ; ne može ponašanje istodobno biti dopušteno i nedopušteno
- 2.) Također ponašanje ne može biti istovremeno dopušteno i zabranjeno
uporaba dopuštenja bila bi kršenje zabrane, pridržavanje zabrane ne bi bilo kršenje dopuštenja jer se dopuštajuće norme može uporabiti ili ne uporabiti, ali ih se ne može pridržavati niti ih se može kršiti
- 3.) Isto tako ponašanje ne može istodobno biti obvezno i neobvezno
uporaba neobveznosti bila bi kršenje obveze, ali pridržavanje obveze ne bi bilo kršenje neobveznosti
- 4.) Ne može biti ni istodobno zabranjeno i obvezno; izvršenje jedne bilo bi kršenje druge norme
- 5.) Obvezno implicira dopušteno; ako je radnja obvezna onda je dopušteno izvršiti
- 6.) Dopuštenje i neobveznost su spojivi; spoj dopuštenja činiti i neobvezanosti ne činiti je ono što se naziva slobodom

4. Zapovijedane norme i dopuštajuće norme u normativnim sustavima

izvršavaju različite funkcije;

- Na razini običnih normi o ponašanju građana - **zapovjedne** norme izvršavaju glavnu funkciju, a **dopuštajuće** norme sporednu; bez zapovjednih normi nema pravnog poretka
- Na razini normi o proizvodnji normi
zapovjedne norme igraju sporednu ulogu (služe za ograničavanje ili razgraničavanje dodijeljene normativne vlasti)
dopuštajuće norme izvršavaju glavnu funkciju (sredstva za ustanovljenje normativnih vlasti)

5. Zapovjedne norme i sankcionirajuće norme

- **sankcija** = prisilno oduzimanje nekog dobra kao što je život, sloboda ili vlasništvo
 - između zapovjednih (zapovijedi i zabrane) i sankcionirajućih normi postoji dvostruko logički odnos:
- 1.) **Zabrane i sankcije** - kaznenopravne norme formulirane su kao sankcionirajuće norme
 - one nisu upućene građanima nego sucima zapovijedaju da sankcioniraju kaznena dijela
 - Ako je neko ponašanje sankcionirano, onda je zabranjeno
 - **sankcija** je dovoljan uvjet zabrane (ne postoji sankcija bez zabrane)
 - 2.) **Zapovijedi i sankcije** – zakonodavac može formulirati zapovijed, a da ne poveže sankciju uz to
 - Ako propuštanje nekog ponašanja nije sankcionirano, onda to ponašanje nije obavezno
 - sankcija je nužan uvjet za zapovijed (ne postoji zapovijed bez sankcije) → međusobno se impliciraju

6. Uporaba i navođenje deoničkih iskaza

- izraz je **uporabljen** kada se koristi za označavanje onoga što on znači (upravni govor)
- izraz je **naveden** kada se koristi za izvješćivanje i citiranje govora drugih (nepravni govor)
- iskazima u kojima je riječ 'obveza' **uporabljena** izražavaju se norme; njima se izravno propisuje
- iskazima u kojima je riječ 'obveza' **navedena** ne propisuje se, izvještava da je zakonodavac propisao

7. Deontički iskazi u spoznajnoj funkciji

Deontički iskaz može se uporabiti:

- 1.) Za izražavanje norme
- 2.) Za potvrđivanje ili ponavljanje norme
- 3.) Za opisivanje sadržaja norme
- 4.) Za pretpostavljanje da postoji neka norma

1. **Prediktivna teza** – jedan je aspekt realističke teorije
 - postoji pojmovni odnos između obveze i sankcije (nema obveze bez sankcije)
 - spoznajni iskazi u kojima se upotrebljuje iskaz "obveza" **bili bi** posve činjenični sudovi bez ikakvog upućivanja na norme
 - **realisti** - smatraju da norma postoji kada je predvidivo da će je sudovi ubuduće primjenjivati
2. **Normativna teza** - jedan aspekt normativističke teorije pravne znanosti
 - ne postoji nužni pojmovni odnos između obveze i sankcije (moguće je postojanje obveze bez sankcije)
 - spoznajni iskazi u kojima se upotrebljuje iskaz "obveza" **ne bi bili** ni činjenični ni predviđajući sudovi, nego egzistencionalni sudovi glede (postojanja) normi
 - **normativisti** - smatraju da norma postoji kada je valjano

VII. NAČELA

1. Pravilo v. načela

- **PRAVILO** - pogodbeni iskaz koji povezuje neku pravnu posljedicu s nekim razredom činjenica
- **NAČELO** - nešto složeniji i prije svega sporan

je svaka norma koja ima:

- 1.) Temeljni karakter
- 2.) I koja je određena osobitim oblikom nadređenosti

2. Načela kao temeljne norme

načela su temeljne norme jer:

- a) jer daju temelj ili vrijednosno (etičko-političko) opravdanje drugim normama
- b) ne zahtijevaju nikakav vrijednosni temelj, vrijednosno opravdanje, jer ih se u postojećoj pravnoj kulturi doživljava kao očividno „pravedne“ ili „ispravne“ norme

3. Načela kao neodređene norme

- ne odnosi se na pravni položaj norme u pravnom poretku, nego na sam sadržaj i logičku strukturu tri različita oblika:

- 1.) **Otvoreno činjenično stanje:** otvoreni antecedent (č.s.); otvoreno je tek primjerično nabranje
- 2.) **Otklonjivost ili derogabilnost:** otklonjive norme (dopušta implicitne iznimke koje nisu utvrđene ni njome ni drugim normama istoga pravnog poretka)
- 3.) **Općenitost:** (npr. Sve ubojice treba kazniti. Petar je ubojica. Petra treba kazniti)
 - a) Zahtijevaju formuliranje drugih normi koje je konkretiziraju, bez kojih ne bi bila prikladna za rješavanje konkretnih slučajeva
 - b) Mogu biti provedene, izvršene ili konkretizirane na mnogo različitih i alternativnih načina

4. Razvrstavanje načela

1.) Razlika ustavnih načela od zakonskih

- **ustavna** su načela apsolutno obvezujuća, **zakonska** mogu ograničiti ili ukinuti samim zakonom
- među ustavnim načelima postoje vrhovna načela koja su apsolutno neizmjenjiva i ne može ih se ograničiti ili ukinuti pa su zato *iznad-ustavna*

2.) Razlika načela koja pokrivaju čitav poredak

- a) *opća načela u užem smislu* – istodobno su i ustavna načela (npr. jednakost, osobna sloboda... onih koja se odnose samo na jedno njegovo posebno područje)
- b) *posebna načela* – neka su ustavnog, a neka zakonskog ranga (npr. ustavnog su: načelo dobre i nepristrane uprave, a zakonskog ranga - načelo pravičnog postupka)

3.) Razlika izraženih načela od neizraženih (implicitnih)

- **Izražena** su ona koja su izrijekom formulirana u posebnoj normativnoj odredbi iz koje se mogu izvesti putem tumačenja (npr. načelo neformalnosti ugovora u tal. pravu);
- **Neizražena** su ona "bez odredbe", koja izrijekom nisu formulirana ni u jednoj normativnoj odredbi nego su ih razvili tumači (npr. načelo zaštite dobre vjere)

VIII. SUBJEKTIVNI PRAVNI POLOŽAJI

1. „Subjektivna dimenzija“ normi

- **SUBJEKTIVNI PRAVNI POLOŽAJ** - subjektivna dimenzija norme, tj. svojstvo koje je subjektu pripisano normom (vlast, sposobnost, nadležnost, zabrana, otpornost, dužnost...)
- **W.N.HOHFELD** - 8 osnovnih (temeljnih) položaja: *zahtjev, obveza, sloboda, ne-zahtjev, vlast, podložnost, bezvlast, otpornost (imunitet)* – **može se razdijeliti u 2 razreda**
 1. 4 subjektivna položaja za predstavljanje općih normi ponašanja građana (primarne norme)
 2. 4 subjektivna položaja za predstavljanje normi o proizvodnji prava (sekundarne norme)
- njima se uređuju načini stvaranja i mijenjanja normi o ponašanju.

2. *Primarni pravni položaji:*

1. **OBVEZA** - pravni položaj subjekta kojemu se upućuje zapovjedna norma (zapovijed ili zabrana)
2. **ZAHTJEV** - pravni položaj subjekta kojemu se normom (ovlaštenja) dopušta da zahtijeva izvršenje obveze od strane drugog subjekta
3. **SLOBODA** - pravni položaj subjekta kojemu se dopuštajućom normom ili normom neobvezivanja dopušta ponašati se na određen način te pravni položaj subjekta kojemu se nijednom zapovjednom normom ne nameće ponašanje na određeni način
4. **NE-ZAHTJEV** – (nepostojanje zahtjeva) pravni položaj subjekta kojemu se normom izrijeком uskraćuje ili oduzima (ranije dan zahtjev) i nijednom normom izrijeком sub se ne dodjeljuje zahtjev
 - *obveze i zahtjevi* - po prirodi su entiteti koje je stvorilo pravo – višeznačajni su
 - *sloboda i nezahtjevi* - pravni položaji lišeni pojmovne autonomije

3. *Sekundarni pravni položaji:*

1. **VLAST** - položaj subjekta kojemu se normom dopušta da stvara ili mijenja primarne pravne položaje u pogledu sebe i drugih subjekata
2. **PODLOŽNOST** - položaj subjekta kojemu drugi subjekt može izmijeniti primarni pravni položaj
3. **BEZVLAST** - nepostojanje vlasti; proizlazi iz postojanja norme kojom se subjekt lišava ranije dodijeljene vlasti i iz nepostojanja ijedne norme kojom mu se dodjeljuje vlast
4. **OTPORNOST** - nepostojanje podložnosti; ono proizlazi iz nepostojanja norme kojom se subjekt oslobađa neke ranije podložnosti i iz nepostojanja ijedne norme kojom mu se nameće podložnost
 - *vlast i podložnost* - po prirodi su entiteti koje je stvorilo pravo – višeznačajni su
 - *bezvlast i otpornost* – pravni položaji lišeni pojmovne autonomije

5. *PRAVNI ODNOS*

- svaki odnos između dvaju subjekata koji je uređen pravnim normama

Dva osnovna tipa pravnih odnosa:

- 1.) uspostavljen općim normama o ponašanju – npr. obveznopravni odnos (između dvaju subjekata)
 - uspostavlja se kad prva norma jednom subjektu nameće *OBVEZU* da se ponaša na određeni način, a druga norma drugom subjektu dodjeljuje odgovarajući *ZAHTJEV*
- 2.) uspostavljen normama o proizvodnji prava; odnos vlasti, uređuje proizvodnja normi o ponašanju
 - uspostavlja se kad prva norma prvom subjektu dodjeljuje *VLAST* stvaranja obveza i zahtjeva u pogledu drugog subjekta, a druga norma drugom subjektu nameće odgovarajuću *PODLOŽNOST*

IX. **PRAVA**

1. i 2. *Višeznačajnost „subjektivnog prava“*

- subjektivni pravni položaji - svojstva koja se subjektima dodjeljuju objektivnim pravom

Osnovni konteksti subjektivnog prava:

- 1.) Pravo ponašati se na određeni način
- 2.) Pravo postići da se drugi ponaša na određeni način
- 3.) Pravo stvarati, mijenjati ili utrnjivati obveze i prava
- 4.) "stvar" – pravo o kojem se govori ponekad za predmet nema ponašanje, nego stvar

3. Višeznačajnost iskaza o pravima (pripisivanje, zahtijevanje, opisivanje prava)

„Subjekti S imaju pravo P“

- 1.) U kontekstu **normativnog dokumenta** - propisujući iskaz; izražava se norma kojom se pozitivno pripisuje (dodjeljuje) određeno pravo nekom razredu subjekta
- 2.) **političkog dokumenta** - zahtijeva se pravo; iskazi propisujućeg diskursa koji se odnose na:
 - a) Neko **pozitivno pravo** zbog čije se povrede prigovara i zbog kojega se zahtijeva slobodno izvršavanje ili zaštita (*de sententia ferenda*)
 - b) Neko **moralno (prirodno) pravo zbog** kojeg se zahtijeva njegovo priznanje i zaštita pozitivnim pravnim poretom (*de lege ferenda*)
- 3.) **doktrinarnog rada** - opisivanje norme kojom se pripisuje neko pravo; uvjet istinitosti sporni zbog:
 - a) Neki smatraju da se za subjektivno pravo može reći da je postojeće samo ako postoji norma kojom ga se dodjeljuje; sud je istinit samo zbog norme
 - b) Drugi da je postojeće samo pod uvjetom da postoji norma kojom ga se dodjeljuje i jedna ili više dodatnih normi kojima se uspostavljaju mehanizmi osig. njegova uživanja i zaštite

4. Sloboda i otpornost

- **Subjektivno pravo** – za predmet ima svoga vlastitoga nositelja – 2 različita položaja izraza:
 - 1.) Subjektivno pravo kao **sloboda** - pravni položaj subjekta kojega ne tereti nikakva obveza
- izraz sloboda može se koristiti na 2 načina:
 - a) Jednom dopuštajućom normom i/ili normom neobvezivanja dopušta ponašati se na određen način
 - b) Nijednom zapovjednom normom ne zapovijeda ili ne zabranjuje ponašati se na određen način
- 2.) Subjektivno pravo kao **otpornost** - odnosni pojam koji znači nepostojane podložnosti jednog subjekta u odnosu na drugog; višeznačnost otpornosti – koristi se za:
 - a) označavanje pravnog položaja subjekta kojemu se **normom** pozitivno **dodjeljuje otpornost**
 - b) označavanje pravnog položaja subjekta kojemu se **nijednom normom ne nameće podložnost**

5. Subjektivno pravo kao zahtjev

- u ovom smislu označava kao odnos između dvaju različitih subjekata:
- norma kojom se određenom subjektu (npr. vjerovniku) dodjeljuje zahtjev, podrazumijeva normu kojom se nekom drugom subjektu (npr. dužniku) nameće obveza
- postoji slabi smisao slobode i otpornosti, ali ne postoji slabi smisao zahtjeva

6. Subjektivno pravo kao vlast

- **Vlast** sposobnost mijenjanja vlastitih ili tuđih pravnih položaja; u korelaciji je sa podložnošću
- **podložnost vlasti** mogućnost trpljenja mijenjanja vlastitog pravnog položaja djelovanjem drugih
- ne postoje vlasti bez normi kojima ih se dodjeljuje, ni podložnosti bez normi kojima ih se nameće

7. Subjektivno pravo kao složeni položaj

- Subjektivno pravo koje za predmet ima neku 'stvar' ; stvarna prava – mnoštvo os sub položaja
- **pravo vlasništva**= skup mnoštva subjektivnih pravnih položaja vlasnika i skup različitih sloboda, vlasti, otpornosti i zahtjeva

8. Prava drugog stupnja

funkcionalno su povezan s drugim pravima:

- 1.) Ustavno pravo jednakosti - ima za predmet jednaku razdiobu prava (bez razlike na spol, rasu, jez)
- 2.) Pravo na tužbu - u funkciji je zaštite nekog drugog prava (npr. subjektivnog obveznog prava)
- 3.) Vlast - mijenjanje vlastitih i tuđih prava

9. Pravo kao zaštićeni subjektivni položaj

- proizlazi iz spoja dvaju različitih subjektivnih položaja:
 1. s bilo kojeg od prethodno nabrojenih subjektivnih položaja (slobode, otpornosti, zahtjeva...)
 2. pravo na tužbu, odnosno prava obratiti se sudskom organu radi zaštite dotičnog sub položaja

10. Izvor prava

- Prava se mogu svrsishodno razlikovati prema izvoru iz kojega proizlaze:
 - 1.) **Ustavna prava**; dodijeljena ustavom - pojedincima dodijeljena prema državi (protiv nje) i u tom su smislu "javna" prava, ali mogu se isticati i prema građanima (erga omnes)
 - 2.) **Zakonska prava**; dodijeljena zakonom (u krutim ustavima hijerarhijski podređen ustavu)
 - 3.) **Ugovorna prava**; proizlaze iz ugovora - pojedincu dodijeljena prava prema drugom pojedincu i u tom smislu "privatna" prava

11. Temeljna prava

- prava dodijeljena ustavom → prava građana prema državi, "subjektivna javna" prava

Razlike ustavnih prava:

1.) Sadržaj prava:

- a) **Prava na slobodu** - spoj različitih "prava"; npr. pravo na slobodu je spoj slobode ponašanja na određeni način, otpornosti prema zabranama zakonodavaca, zahtijeva za propuštanje izvršne vlasti da fizički spriječi dotično ponašanje
- b) **Socijalna prava** („prava na papiru“) - mogu se shvatiti kao zahtjev kojemu odgovara neka obveza države; obveza usvajanja zakona, donošenja upravnih akata i izvršavanja materijalnih radnji prikladnih za ostvarivanje takvih zahtjeva

2.) Nositeljstvo prava:

- a) **Ljudska prava** - prava koja se bez razlike dodjeljuju svim ljudima, neovisno o državljanstvu (npr. pravo očitovanja vlastite vjere, pravo izražavanja vlastite misli...)
- b) **Građanska prava** - ona koja se dodjeljuju samo građanima (npr. pravo glasa)

12. legitimni interes

- u općoj uporabi se odnosi na 2 subjektivna položaja pojedinca u odnosu na javnu upravu:
 1. „**očekujući interes**“ - tzv „od slučaja do slučaja zaštićen interes“ ili
 2. „**suprostavljani interes**“ - oslabljeno pravo, degradirano pravo

Drugi dio

PRAVNA DINAMIKA

I. NORME O PROIZVODNJI PRAVA

1. Pravo uređuje vlastito stvaranje

- **Pravo** - među ostalim uređuje i svoje vlastito stvaranje i primjenu
- **Norme o proizvodnji prava** - norme koje uređuju stvaranje drugih normi, norme o nadležnosti imaju formalan karakter, u smislu što se njima propisuje:
 - a) Koji organ je nadležan stvarati i ukidati norme
 - b) U kojem postupku on treba izvršavati tu nadležnost

Razred formalnih normi o zakonodavstvu obuhvaća:

- 1) Norme kojima se dodjeljuje zakonodavna nadležnost
- 2) Norme kojima se uređuje izvršavanje te nadležnosti (norme u zakonodavnom postupku)

2. Norme o nadležnosti

- sve norme kojima se određenom organu pripisuje **normativna vlast** (vlast stvaranja pravnih normi)
- njima se **ne dodjeljuje** opća normativna vlast, **dodjeljuje se** vlast *jednog točno određenog izvora prava*, tj. normativnog dokumenta koji ima svoje vlastito ime (**nomen juris**); imaju dva aspekta:
 - 1) Njome se **ovlašćuje** neki organ da stvori neku određenu vrstu izvora prava
 - 2) Njome se **definira** (pridonosi definiranju) dotični izvor prava

3. Norme o postupku - imaju dva aspekta:

- 1) Njome se **propisuje** prihvaćanje određenog postupka za stvaranje određenog izvora prava
- 2) Njome se **definira** (pridonosi definiranju) dotični izvor prava

II. PRAVNI IZVORI

1. Pojam pravnog izvora

„Ako Č onda P“ → P = nastanak novih pravnih normi, **novog prava**

- **antecedent** = razred uvjetujućih činjenica, **konsekvent** = razred pravnih posljedica

”Ako subjekt S odluči x, onda je x pravo” → **konsekvent** = proizvodnja prava, **antecedent** = izvor prava

2. Implikacije – 3 pojma izvora prava

- 1) **Općeteorijski** - podrazumijeva da svaki pravni poredak ima svoje vlastite izvore i za utvrđivanje izvora prava nije „općeteoretsko pitanje, već ”dogmatsko” (pitanje pozitivnog prava)
- 2) **Formalni** - utvrđuju se na temelju vanjskih obilježja, poput postupka proizvodnje i/ili *nomen juris*
- 3) **Relativizacija** pojma (poz) prava - sve određeno nekim normativnim dok. npr. zakonom čini pravo

3. Razjašnjenja

dva standardna načina formuliranja normi u proizvodnji prava:

- 1) dodjeljivanje nekom sub. normativne vlasti, tj. vlasti stvaranja određenih dok. pravila ponašanja
- 2) pripisivanje nekom subjektu vlasti ”uređivanja” nečega

4. *Tijela vlasti, postupci, dokumenti*

Elementi procesa proizvodnje prava:

- a) **tijelo normativne vlasti** (normotvorac) - subjekt koji ima vlast stvaranja prava – zakonodav org.
- b) **normativni postupak** - slijed akata čiji je ishod proizvodnja prava – npr. zakonodavni postupak
- c) **normativni dokument** - proizvod normativnog postupka - npr. zakonodavni dokument
- izvor prava: postupak, dokument-ne i tijelo vlasti-1 t. vl može biti izvor različitih izvora npr. Hr sabor

III. **IZVORNI IZVORI**

1. *Izvorne norme i izvedene norme*

- **IZVORNE NORME** (vrhovne, neovisne, suverene)
- pripadnost pravnom poretku *NE* ovisi o postojanju drugih normi; ustavne norme, tj norme prvog ustava (nisu izvedene iz nekih drugih normi) - njima se dodjeljuju ili uređuju **zakonodavna vlast**
- **IZVEDENE NORME** (ovisne o drugim normama) - ostale norme; one čije postojanje počiva na prethodnom postojanju drugih normi – njima se dodjeljuju ili uređuju **uredbodavne vlasti**
- primarno=zakoni, sekundarno=uredbe

2. *Utemeljenje norme*

- **Dinamika** pravnog poretka - procesi proizvodnje prava
- **Statika** pravnog poretka - sadržaj pravnog poretka, kakav on jest u danom trenutku
- 1) N1 je norma nadležnosti kojom se tijelu vlasti T daje nadležnost stvaranja N2
- 2) N1 daje statički temelj N2 kada je N2 neizražena norma izvediva log ili argum sredstvima iz N1

3. *Izvorni izvori i izvedene izvori*

- **IZVEDENI izvori** - pravni izvori; činjenice koje su predmet uređivanja normi o proizvodnji prava (npr. zakoni, uredbe) - plod utemeljenih vlasti, izvedene dinamički iz norme
- **IZVORNI izvori** – prvi ustav – vlast koja nije ni dodijeljena ni određena nijednom normom

4. *Kriterij pripadanja poretku*

- **Izvedene** – na temelju normi u proizvodnji kojima se uređuje njihovo stvaranje
- **Izvorne** – zato jer ga definiraju, određuju mu granice, te ako su društveno učinkovite

5. *Društvena učinkovitost ustavnih normi u nadležnosti*

- **društvena učinkovitost** - skup normi o zakonodavstvu, norma kojoj se uobičajeno pokorava norma o nadležnosti je učinkovita ako:
 - 1) njome se izvršava dodijeljena normativna nadležnost
 - 2) propisi su proizvedeni izvršavanjem te nadležnosti učinkoviti, tj da im se redovito pokorava

IV. **NORMATIVNI AKTI I NONORMATIVNE ČINJENICE**

1. *Sugestivno razlikovanje* 2. *Normativni akt* 3. *Normativno činjenica*

- u doktrini razlikujemo 2 glavna razreda izvora prava:

- 1) **NORMATIVNI AKT** - ona ponašanja kojima se norme proizvode svjesno i voljno; formulirano pravo (uglavnom pisano)
 - a) Označava **radnju**: djelovanje kojim se proizvode norme, npr. donošenje zakona
bolje je reći normativni **postupak**
 - b) Ne označava djelovanje nego **rezultat** djelovanja: npr. sam zakon → normativni **dokument**
- 2) **NORMATIVNA ČINJENICA** - ljudsko ponašanje kojom se proiz. pravne norme -nepisano pravo
 - a) ona ponašanja kojima se norme ne proizvode svjesno i voljno; neformulirano i nepisano pravo (glavno značenje)
 - b) **izvori "extra ordinem"**, tj. izvorne činjenice koje daju život normama kojima adresati daju pristanak i koje postaju vrijedeće na temelju „načela efektivnosti“
 - c) **normativni akti vanjskih pravnih poredaka** čije su norme povremeno primjenjive na temelju upućivanja

4. Običaj

- pojam **običaj** -navike (pravilnost ponašanja) - stalna društvena praksa koja se ponavljanja tijekom duljeg razdoblja popraćenu uvjerenjem da ta praksa podliježe obvezujućoj normi; sastoji se od:
 - a) materijalnog elementa - izvanjski opažljivog ponašanja
 - b) psihološkog elementa - uvjerenja ili normativnog stava
- **običajno pravo** je sudačko pravo (pravo koje stvaraju suci)
- autonomija i decentralizacija proizvodnje normi

5. Pravni izvori i izvori extra ordinem

- **Normativne činjenice** su jedino one koje samo pravo ovlašćuje za proizvodnju prava
- **NORMATIVNA ČINJENICA KAO PRAVNI IZVOR** - kada je norma o proizvodnji prava uzima kao uvjetujuće činjenično stanje nastanka novog prava
- **NORMATIVNA ČINJENICA KAO IZVOR „EXTRA ORDINEM“** - kada "proizvodi pravo" unatoč nepostojanju normi o proizvodnji prava, npr. izobičajenje → *načelo efektivnosti*

6. Načelo efikasnosti- ono pravilo na temelju kojega:

- a) normu treba smatrati pravno postojećom kada je njezini adresati općenito prihvaćaju i pridržavaju se
- b) normu se ne može smatrati pravno postojećom - njezini adresati ne prihvaćaju i ne pridržavaju se

V. ZAKON

1. različita uporaba izraza „zakon“

- 1) uporaba u vezi s nenormativnim pojavama – ponekad označava **pravilnost događanja i ponašanja**, ponekad **znanstveni iskaz** kojim se opisuje ta pravilnost, a ponekad **obje stvari**
- 2) uporaba s normativnim pojavama – povremeno označava jedan propisujući iskaz (**odredbu**), a češće skup propisujućih iskaza (**normativni tekst**)

- 2. Zakon u općenitom smislu:**
- a) kao istoznačnica za pravo (u objektivnom smislu)
 - b) istoznačnica za izvor prava *par excellence*

3. Zakon kao primarni i vrhovni izvor

1. **zakon kao izraz "opće volje"** – najviša, suverena vlast (europska pravna misao 19.-20.st - Fra)
 - b) zakon kao vrhovni izraz - **nadređen** drugim izvorima
 - c) zakon kao primarni izraz - izvorni izvor; zakonodavna funkcija logički **predodređena** svakoj drugoj državnoj funkciji – jedina koja ne predstavlja primjenu već postojećih normi
2. **zakon izvor prava par excellence** – počevši od Francuska revolucija
 - a) shvaćanje prava kao općih i apstraktnih normi upućenih građanima
 - b) shvaćanje zakonodavne funkcije kao vlasti uređivanja ponašanja građana putem općih normi

4. Zakon u formalnom i materijalnom smislu

1. **zakon u formalnom smislu** - svaki akt ili dokument koji potječe od zakonodavnog organa i ima posebno pravno uređenje (razlikuje se od akta izvršne vlasti i sudske vlasti)
2. **zakon u 1. materijalnom smislu** - svaki akt ili dokument kojim se izražavaju opće i apstraktne norme
3. **zakon u 2. materijalnom smislu** - svaki akt ili dokument kojim se uređuje ponašanje građana (nema nužno opći ili apstraktni sadržaj)

5. Načelo zakonitosti

- načelo podvrgnutosti javnih vlasti zakonu
- 1) u **formalnom** smislu zakona; sudska i izvršna vlast - načelo zakonitosti je prirodna posljedica one političke doktrine koja u zakonu vidi izraz opće volje
 - 2) u **materijalnom** smislu zakona; sudska, izvršna i zakonodavna vlast (pod uvjetom da je ustav krut) - – zakon je ovdje ništa drugo nego objektivno pravo

podvrgnutost zakonu predstavlja se različito ovisno o državnoj vlasti o kojoj se govori:

1. **načelo ustavnosti** - podvrgnutost zakonu u materijalnom smislu zakonodavne vlasti
 - a) treba biti donošen u ustavno propisanom obliku
 - b) treba određivati u okviru svoje nadležnosti
 - c) ne može određivati suprotno ustavu
2. **načelo zakonitosti pravosuđenja** - podvrgnutost (formalnom) zakonu sudske vlasti
 - sastoji se od bezuvjetnoj dužnosti primjenjivanja zakona – suci ne mogu odbiti primjenu zakona
3. **načelo zakonitosti u pravom smislu riječi** - podvrgnutost (formalnom) zakonu izvršne vlasti
 - u pogledu kaznenog prava vrijedi načelo slobode, za upravu vrijedi načelo zakonitosti u užem smislu
 - utemeljenost akta uprave na zakonu i njihova sukladnost zakonu

II. KOLOKVIJ

Treći dio

USTAV I USTAVOTVORNA VLAST

I. USTAV

1. Četiri uporaba izraza „ustav“: (+potpoglavlja 3, 4, 5, 6,7)

1. **Skup političkih činjenica** (političko uređenje) - stvarni događaji u političkom životu države
 - shvaćanja: 1.) neki političko uređenje shvaćaju kao skup političkih ciljeva
 - 2.) drugi kao stvarno strukturu i funkcioniranje pol. inst. u različitim pov. stad.
 - 3.) ostali naprosto kao skup odnosa među političkim strankama
2. **Skup normi o "obliku države"** - norme o ustrojstvu vlasti i o odnosima državljana i građana
 - uključuje: a) norme kojima se određuju centralni organi države i temeljne funkcije
 - b) norme kojima se uređuju međusobni odnosi tih organa
 - c) norme kojima se određuju i dodjeljuju funkcije necentralnim i lokalnim org
 - d) norme kojima se uređuju načini formiranja prethodno navedenih organa
 - e) norme koje uređuju odnose između (centralnih i lokalnih) organa i građana
 - nemaju nužno sve drž. ustav (u smislu ustavnog kodeksa) npr. VB -ustavno pravo običajno
3. **Određeni normativni dokument** - "kodeks" ustavne materije njime kodificiraju i formuliraju norme iz prethodne točke - ustav se od ostalih normativnih dokumenata razlikuje
 - razlike: a) prvenstveno po **nazivu** – nije tip, razred već jedan normativni dok, jedini
 - b) po svom karakterističnom **sadržaju** – u većem dijelu *materijalno ustavan*
 - c) po svojim tipičnim adresatima – upućen ne građ, nego vrhovnim ustavnim org
4. **Posebna vrsta političkog poretka** – poredak liberalnog tipa, u kojem je politička vlast ograničena posebnim *ad hoc* normama
 - dioba vlasti + jamčenje građanskih prava—država je ustavna samo ako su u njoj zajamčena prava građana prema državi i ako su vlasti države razdijeljene i odvojene
 - **materijalno ustavne** norme mogu biti pisane ili običajne – postoje pisani ustavi gdje određene norme koje se smatraju „materijalno ustavnima“ nisu zapisane (npr. izborne norme) - postoje i pisani ustavi koji uključuju norme koje nisu „materijalno ustavne“

2. Umetak: „formalni“ ustav i „materijalni“ ustav

FORMALNI USTAV	MATERIJALNI USTAV	
Skup normi kojima se određuje oblik države	Skup političkih činjenica	Istom formalnom ustavu mogu odgovarati različiti materijalni ustavi
ILI		
Određeni normativni dokument	Skup normi o obliku države	Ne postoji nužno formalni ustav . Ukoliko i postoji, ne obuhvaća nužno u potpunosti materijalni ustav

- **Materijalno ustavne norme** - one kojima se određuje oblik države
- **Ustavna materija** - oblik države, tj. ono što je uređeno materijalno ustavnim normama
- „Ustavna“ je drž kada su: 1) zajamčena prava građana prema državi
- 2) vlasti drž (zakonodavna, izvršna i sudska vlast) odvojene

8. Vrste ustavnih normi

- 1) **norme o ustrojstvu** - norme kojima se ustanovljuju organi, određuju načini njihova formiranja i uređuju njihovi međusobni odnosi
 - 2) **norme o nadležnosti** - norme kojima se dodjeljuju vlasti
 - 3) **norme kojima se (ljudima i/ili građanima) pripisuju subjektivna prava** - ograničava se nadležnost državnih organa (osobino zakonodavne vlasti)
 - 4) **norme-načela i programatske norme** - norme kojima se usmjerava izvršavanje vlasti
- prve dvije vrste normi imaju u ustavnim dokumentima vodeću ulogu

9. TEHNIKE OGRANIČAVANJA VLASTI svrha ustava je ograničiti političku vlast	
podvrgavanje vlasti normama o ponašanju:	stvaranje protuvlasti "vlast zaustavlja vlast" (Montesquieu)
upućivanje smjernica, zapovijedi i zabrana državnim organima → tzv. programatske norme	npr. Hrvatski sabor (zakonodavna vlast) ← Ustavni sud (protuvlast ukidanja zakona)

10. Dva modela ustava

1. **normativni model ustava** ("ustav kao **norma**") - jamčenje građanskih prava skupom zapovijedi i zabrana upućenih državnim organima - norme o dobrom zakonodavstvu (i dobroj upravi)
2. **mehanički model ustava** ("ustav kao **stroj**") - jamčenje građanskih prava skupom normi o ustrojstvu i nadležnosti - sustav provjera i ravnoteža (checks and balances- otežavanje kršenja prava)

11. Ustav kao izvor prava - tri različita načina shvaćanja te teze:

- 1) ustavnim iskazima izražavaju se pravne norme
- 2) ustav izvor prava –ustavne norme mogu:
 - a) ukinuti ili učiniti nevaljanima s njima materijalno nespojive ranije norme nižega ranga
 - b) učiniti nevaljanima s njima formalno ili materijalno nespojive kasnije norme nižega ranga
- 3) ustavne norme mogu neposredno uređivati i "vodoravne" privatnopravne odnose

II. USTAVOTVORNA VLAST

1. Utemeljene vlasti i ustavotvorna/utemeljujuća vlast

- **utemeljena** (konstituirana) vlast - "pravna" vlast; dodijeljena i uređena vrijedećim pozitivnopravnim normama
- **utemeljujuća/ustavotvorna** (konstitutivna) vlast -"činjenična" vlast; kojom se uspostavlja "prvi ustav"- kriterij pravnog postojanja prvog ustava je društ učinkovitost (*efektivnost*)

2. Dva shvaćanja ustavotvorne vlasti

1. **Formalističko** - vlast koja se izvršava *extra ordinem*, tj. u nezakonitim oblicima - ustav je konačan skup normi
2. **Supstancijalističko** - vlast koja **određuje oblik države** - ustav je povezana ukupnost načela i/ili vrijednosti

3. Dva različita shvaćanja ustava

- 1) **formalističko shvaćanje** - ustav (kao skup normi) gubi svoj identitet i preobražava se u različiti skup uvođenjem nekog novog elementa ili uklanjanjem postojeće
 - svakom izmjenom proizvodi se "novi" ustav - važno je razlikovati **zakonite** (one izvršene u obliku predviđenom samim ustavom na snazi) od **nezakonitih** (extra ordinem) **izmjena**
- 2) **supstancijalističko shvaćanje** - ustav (kao povezana ukupnost načela) zadržava svoj materijalni identitet sve dok se ne izmijene vrhovna načela koja ga tvore
 - važan predmet, a ne toliko način mijenjanja

Dva shvaćanja mijenjanja ustava:

- 1) **sa supstancijalističkog gledišta** - mijenjanje vrhovnih načela je uspostava novog ustava
 - vrhovna načela postojećeg ustava su "logičke" granice mijenjanja ustava
 - ne postoje zakoniti načini preoblikovanja, samo u nezakonitom obliku, revolucionarnim putem
- 2) **sa formalističkog gledišta** - promjena ustava u zakonitom obliku (bez obzira na predmet) je puko mijenjanje ustava (iako se zapravo formalno stvara "novi" ustav)
 - ne postoje logičke granice mijenjanja ustava - ustav može biti temeljito preoblikovan u zakonitim oblicima (bez revolucije)
 - **zakonsko** mijenjanje ustava izvršavanje je utemeljene vlasti, a **nezakonsko** ustavotvorne

4. Mijenjanje normi o mijenjanju

- 1) norme o mijenjanju ustava **ne može** se izmijeniti u postupku mijenjanja ustava → argument: norma se ne može razumno odnositi na sebe samu a da ne proizvede nerješivo proturječje → N1 temelj valjanosti N2; N2 proturječi N1
 - 2) norme o mijenjanju ustava **može** se izmijeniti u postupku mijenjanja ustava
1. **argument:** norma može proturječiti normi iz koje dinamički crpi valjanost (meki ustav!)
 2. **argument:** N1 i N2 nisu na snazi u istom trenutku (pripadaju različitim ustavima)

III. TIPOLOGIJA USTAVA

prema: 1) **obliku** - pisani i običajni

- 2) **načinu donošenja** - oktroirani ustavi, ustavni paktovi, savezni ustavi, narodni ust
- 3) **uređenoj materiji** - kratki (ustrojstvu i raspodijeli vl) i dugi (povelju o građ pravima)
- 4) **načinu mijenjanja** - meki i kruti

2. Načini mijenjanja ustava

- 1) **meki ustavi** - mogu se mijenjati ili im se može ograničiti doseg običnim zakonom
- 2) **kruti ustavi** - mogu se mijenjati ili im se može ograničiti doseg samo ustavnim zakonom
 - a) **mek ustav** - ako je u pisanom ustavu predviđeno njegovo mijenjanje ili preinačavanje
 - b) **apsolutno neizmjenjiv** (*okamenjen*) ustav → ako je u pisanom ustavu apsolutno zabranjeno mijenjanje istoga
 - c) **kruti ustav** - pisanim ustavom predviđeno je i omogućeno mijenjanje ustava ali je podvrgnuto postupku složenijem od onoga koji se zahtijeva za donošenje zakona
 - d) **djelomično kruti**, djelomično neizmjenjivi ustavi - ako se strogo zabranjuje mijenjanje nekih ustavnih odredbi ili normi
 - e) **prešutno neizmjenjiv ili prešutno mek** - niti dopuštaju mijenjanje niti ga zabranjuju

3. Kvantitativni karakter krutosti i 4. Zajamčeni ustav

- stupnjevito svojstvo po kojemu ustav može biti više ili manje krut, tj. više ili manje mek
- **ZAJAMČENI USTAV** - oni kojima se predviđa poseban postupak njihova mijenjanja i neki oblik ustavnog sudovanja, tj. sudskog nadzora ustavnosti zakona
- **USTAVNO SUDOVANJE** - tehnika jamčenja ustavne krutosti

5. Tri vrste jamstva:

- 1) svaki sud ovlašten odbiti primjenu neustavnog zakona (SAD) - *a posteriori*, nadzor se izvršava u difuznom obliku (ne postoji poseban ustavni sud), *inter partes* (među strankama)
- 2) poseban organ koji preventivno nadzire ustavnost zakona (Francuska do 2008.)
 - nadzor nad zakonima izvršava se *a priori*, tj. nad aktima koji još nisu na snazi
 - nadzor se izvršava u centraliziranom obliku (postoji poseban ustavni sud koji je jedini nadležan nadzirati ustavnost zakona), *erga omnes* (prema svima)
- 3) poseban organ koji naknadno nadzire ustavnost zakona (većina europskih država, uključujući RH) - *a posteriori*, centralizirani oblik, *erga omnes*

6. NADZOR „a priori“ i „a posteriori“ – 2 osnovne razlike

- a) **sa stajališta pravne sigurnosti** – tj. predvidljivosti pravnih odluka
 - **a priori nadzor**: u svakom trenutku skup valjanih pravnih normi je postojan i spoznatljiv podatak
 - **a posteriori nadzor**: nijednu se zakonsku odredbu ne može smatrati konačno valjanom
- b) **sa stajališta jamstva nadređenosti ustava** –
 - **a priori nadzor** - sprječava stupanje na snagu neustavnih zakona
 - **a posteriori nadzor**: neustavan zakon se primjenjuje dok ga nadležni sud ne proglasi neustavnim

7. Centralizirani nadzor v. difuzni nadzor

Dvije osnovne razlike:

- 1) **s aspekta pristupa ustavnom sudovanju** - **difuzni nadzor**: pristup ima svaki građanin
 - **centralizirani apriorni nadzor**: pristup imaju samo neki ustavni organi
 - **centralizirani aposteriorni nadzor**: pristup, u pravilu, imaju redovni sudovi
- 2) **s aspekta pravnih učinaka o neustavnosti zakonskih odredbi** - **difuzni nadzor**: učinci *inter partes*
 - **centralizirani apriorni i aposteriorni nadzor**: učinci *erga omnes*

IV. POUSTAVLJENJE PRAVNOG PORETKA

1. Poustavljenje: u kojem smislu?

Tri značenja poustavljenja:

- 1) uvođenje prvog pisanog ustava u neki pravni poredak koji ga ranije nije imao
- 2) povijesno-kulturni proces (17/18.st) - odnosa između suverena i podanika pretvorio u pravni odnos
- 3) proces preobrazbe pravnog poretka čijim okončanjem dotični poredak biva potpuno „natopljen“ ustavnim normama - uvjetovanost ustavom zakonodavstva, sudske prakse, privatnih odnosa, doktrinarnog stila, političkog života

2. *Uvjeti poustavljenja:*

- 1) „**dugi ustav**“ - onaj koji sadrži odredbe o ustrojstvu javnih vlasti i odredbe kojima se dodjeljuju prava, odredbe-načela i programatske odredbe
- 2) **Krutost ustava** – nadređen običnom zakonodavstvu, kojim ne može biti ograničen u svom doseg, izmijenjen ili ukinut
- 3) **Sudsko jamstvo ustava** - bez jamstva ustava ne postoji „stvarna“ krutost (mora postojati tijelo koje će nadgledati da li je zakon u skladu s ustavom)

ASPEKTI POUSTAVLJENJA su: 1) „**obvezujuća snaga**“ ustava
2) „**nadtumačenje**“ ustava
3) **Neposredna primjena ustavnih normi**
4) **Prilagođujuće tumačenje zakona**
5) **Utjecaj ustava na političke odnose**

1. „OBVEZUJUĆA SNAGA“ USTAVA

- USTAV-pol „proglas“, konkretizira isključivo zakonodavac, sudovi ne mogu primjeniti ustavne norme
- svaka ustavna norma je prava pravna norma, obvezujuća i sposobna proizvoditi pravne učinke
- ustavne norme su obvezujuće i pravno djelovne

2. NADTUMAČENJE USTAVA

- ustav je „konačan“ i ograničen tekst – neizbježno sadrži praznine - ustavnopravno „prazan“ prostor – zakonodavna diskrecija – nepodložnost nadzoru ustavnosti
- nadtumačenje = tumačenjski stav kojim se nastoji otkloniti nepotpunost ustavnog prava
- sprječavanje praznina, izgradnja neizraženih normi za popunjavanje praznina – sredstvo NT-a: ustavne odredbe shvatiti kao načela – nijedan zakon ne može izmaknuti nadzoru ustavnosti

3. NEPOSREDNA PRIMJENA USTAVNIH NORMI

LIBERALNO SHVAĆANJE	KONSTITUCIONALIZAM
ograničenje političke (državne) vlasti (osobito zakonodavne vlasti) ustavne norme uređuju samo ustrojstvo državne vlasti—suci na privatnopravne odnose primjenjuju samo zakone	je oblikovanje građanskog društva, društ. odnosa zakonodavstvo samo razrađuje ustavna načela— svaki sudac može neposredno primijeniti ustavne norme—osobito ako je zakon nepotpun ili nudi nepravedno rješenje

4. PRILAGOĐUJUĆE TUMAČENJE ZAKONA

- tumačenje zakona u skladu s ustavom
- Po jednom tumačenju N1 proturječi ustavu, po drugom N2 je sukladna ustavu
- Izbor tumačenja je na sucu; može dotičnu odluku protumačiti na prvi način i smatrati je neustavnom, ili na drugi način i smatrati je u skladu s ustavom. To drugo tumačenje naziva se „**prilagođujuće**“ - ono kojim se zakon usklađuje ustavom - **učinak** je očuvanje valjanosti zakona

5. UTJECAJ USTAVA NA POLITIČKE ODNOSE - S obzirom na:

SADRŽAJ USTAVA	STAV SUDOVA	STAV USTAVNIH ORGANA I POLITIČKIH ČIMBENIKA
• nadležnost ustavnog suda da rješava sukobe • nadležnosti između najviših tijela vlasti (ustavnih organa)	• nadziranje pol. diskrecije parlamenta (načelo jednakosti + odvagivanje načela)	• U argumentaciji mogu za opravdanje svojih postupaka i odluka uporabljivati ustavne norme više ili manje (ili uopće ne uporabljivati)

Četvrti dio

ARHITEKTURA PRAVNOG PORETKA

I. POJMOVI PORETKA

1. Pojmovi 2. Pravni poredak kao skup normi 3. Pravni poredak kao ukupnost institucija

- Dva različita shvaćanja pravnog poretka
 - 1) Prema standardnom načinu gledanja - **skup normi**
 - 2) Prema drugom načinu gledanja - **ukupnost institucija**
- 1. **Pravni poredak kao SKUP NORMI**
 - a) shvaćen kao skup odredbi
 - b) kao skup normi u pravom smislu riječi
- pravo je diskurs zakonodavstva, tumačenja i pravnog konstruiranja
- 2. **Pravni poredak kao UKUPNOST INSTITUCIJA**
 - Pravni poredak čini skup ustavnih organa – poč. 20.st iznio tezu Santi Romano
 - institucije postoje jer su normama pripisane
 - (npr. Hrv. sabor postoji jer postoji norma koja govori da zakone donosi Hrv. sabor)

4. Pravni poredak kao „sustav“

1. Pravo je normativni poredak ponašanja - uređuje ponašanje (zapovijeda i dovodi u red)
 2. Pravo sam uređeni skup normi: sustav – logički dosljedna, vrijednosno povezana cjelina
 - a) Vrijednosna suvislost - sve norme koje pripadaju pravnom poretku svedive su na jedno načelo ili vrijednost
 - b) Logička dosljednost - odsustvo antinomija, logičkih sukoba, nespojivost između normi
- pravni sustav upotrebljuje se za označavanje pravnog poretka u njegovoj sveukupnosti

II. NORMATIVNE HIJERARHIJE

1. Koji hijerarhijski odnosi?

- **Kelsen** zamišlja samo jedan tip hijerarhijskog odnosa između normi: onaj između normi o proizvodnji prava i s njima u skladu proizvedenih normi
- ustavne norme o zakonodavstvu nadređene zakonodavstvu čak i kada je ustav mek
- **Merkl** - postoji i drugi tip hijerarhijskog odnosa: između dviju normi u kojemu jednoj od njih druga ne može valjano proturječiti, ograničiti joj doseg ili je ukinuti
- ustav nadređen zakonodavstvu samo ako je ustav krut
- **Meki ustav** - nevaljan zakon je onaj koji nije proizveden u skladu s ustavom propisanim postupkom
- **Kruti ustav** - nevaljan zakon je onaj
 - a) koji nije proizveden u skladu s ustavom propisanim postupkom
 - b) čiji je sadržaj u suprotnosti s ustavnim normama

2. Teorija normativnih hijerarhija – 4 vrste

- 1) **Strukturne ili formalne hijerarhije** - odnose se na dinamičku strukturu pravnog poretka
 - one između normi o proizvodnji prava i normi čija je proizvodnja njima uređena
 - N1 norma o proizvodnji prava, a N2 jedna od normi čiju proizvodnju uređuje N1
 - N1 je formalno ili strukturno viša od N2) - hijerarhija postoji na temelju sadržaja same N1
 - 2) **Materijalne ili supstancijalne hijerarhije** - odnose se na sadržaj normi
 - one između dviju normi kada neka treća norma određuje da je jedna od prvih dviju nevaljana ako je u sukobu s drugom - „**hijerarhija izvora**“ - između N1 i N2 postoji materijalni hijerarhijski odnos kada treća pozitivna norma N3 određuje da je N2 nevaljana u sukobu s N1
 - N1 je materijalno viša od N2) - hijerarhijski odnos uspostavlja N3
 - 3) **Logičke ili jezične hijerarhije** - odnose se na jezik: one između dviju normi u slučaju kada se jedna odnosi na drugu
 - između N1 i N2 postoji logički hijerarhijski odnos kada se jednom od njih navodi druga
 - N1 navodi N2 pa je ona logički viša od N2 - hijerarhija postoji na temelju sadržaja N1
 - 4) **Vrijednosne hijerarhije** - odnose se na vrijednosti: one između dviju normi u slučaju kada tumač jednoj od njih pridaje višu vrijednost u odnosu na vrijednost druge
 - između N1 i N2 postoji logički hijerarhijski odnos kada tumač pripisuje N1 veću vrijednost od N2
- Uspostavom vrijednosne hijerarhije između dviju normi proizvodi se jedan od sljedećih učinaka:

1. Ako su dvije dotične norme spojive:
 - a₁) između tih normi postoji odnos opravdanja; N1 (važnija) smatra se temeljem N2, a N2 ostvarenjem N1
 - a₂) odredba kojom se izražava podređena norma bit će oblikovana na način da bude što prilagođenija onoj nadređenoj
2. Ako su dvije dotične norme u sukobu: b₁) uvod je u odluku o neprimjeni niže norme
b₂) uvod je u odluku o smatranju niže norme nevaljanom

4. Normativne hijerarhije i valjanost 4. Metanorma

- formalne i materijalne hijerarhije povezane su valjanošću
- npr. u uređenju mekog ustava nevaljan zakon koji je stvoren na način različit od ustavom propisanog
- s druge strane ne postoji nikakav nužan odnos između valjanosti i logičkih i vrijednosnih hijerarhija
- **METANORMA** - *prima facie*, ona norma koja se odnosi na neku drugu normu većina ih se odnosi na odredbe

5. „Nadređenost“ ustava

Ustav je najviši izvor pravnog poretka u smislu:

- 1) Ustavu ne postoje nadređene norme—on nije niti valjan niti nevaljan (i meki i kruti)
- 2) Ustavom se neposredno ili posredno uređuje proizvodnja ostalih izvora istog pravnog poretka, pa im je strukturno nadređen (i meki i kruti)
- 3) Ne postoji izvor pravnog poretka koji bi mogao valjano proturječiti ustavu materijalno nadređen svim ostalim izvorima (isključivo kruti!)

6. Samoobvezivanje zakonodavca

- U pravnom poretku s mekim ustavom moguće je da zakonodavni postupak bude uređen „običnim“ zakonom
- zakonodavac može sam sebe obvezati

III. VALJANOST, POSTOJANJE, SPOSOBNOST DJELOVANJA

1. Valjanost

- norma je valjana ako je stvorena pridržavanjem svih –formalnih i supstancijalnih—normi kojima se uređuje njihovo stvaranje i ograničava njihov sadržaj – koja je dakle:
 - a) Sukladna je sebi nadređenim normama o proizvodnji prava
 - b) Spojiva sa sebi materijalno nadređenim normama

2. Formalna valjanost i materijalna valjanost

FORMALNO VALJANA	MATERIJALNO VALJANA
• Kada je proizvedena u skladu sa strukturno nadređenim joj normama (onima kojima se uređuje njezino stvaranje) • kada je stvorena na formalno ispravan način što znači—da ju je stvorio nadležni organ prema propisanom postupku	• Kada nije nespojiva s materijalno joj nadređenim normama (onima kojima joj se ograničava ili predodređuje mogući sadržaj)

3. Postojanje

- Dok **valjanost** označava odnos jedne norme s drugim normama, **postojanje** označava odnos pripadanja jedne norme nekom pravnom poretku
- norme su jezični entiteti - činjenično postojanje stječu u trenutku kada su formulirane
- sve norme koje pripadaju pravnom poretku nisu valjane;
 - 1) **Postojeće norme koje nisu ni valjane ni nevaljane**
 - **Ustav** - odnosno „**prvi ustav**“ - proizvod je ustavotvorne/utemeljujuće vlasti **extra ordinem**
 - ne postoje norme kojima se uređuje stvaranje ustava -- ustavne norme su vrhovne, neovisne, izvorne ili suverene; kriterij postojanja tih normi je načelo efektivnosti
 - 2) **Nevaljane norme** – (izražene norme neustavnih zakona i uredbi *contra legem*) - norme koje suci i upravni službenici mogu primjenjivati dok ih nadležni sud ne proglasi nevaljanima
- dovoljan uvjet postojanja je formalna valjanost

4. Sposobnost djelovanja - u dva smisla:

- 1) **Sposobnost provođenja pravnih učinaka** poput: kvalifikacije nekog činjeničnog stanja, stjecanje ili gubitka brava - npr. unatragno djelovanje, djelovanje *inter partes i erga omnes*
 - 2) **Primjenjivost** - norma koja ima sposobnost djelovanja („*djelovna*“ norma) je ona koja se može ili mora primijeniti
- dovoljan uvjet sposobnosti djelovanja je *postojanje norme*

5. Sposobnost djelovanja normi u vremenu

- Vremenski razmak unutar kojeg određena norma treba se primjenjivati – 2 pravila:
 1. Trenutak kada norma stječe snagu (i stoga je treba primjenjivati)
 2. Trenutak kada norma gubi snagu (i stoga je se više ne smije primjenjivati)
- U RH zakon stupa na snagu u trenutku kada je donesen ili 8.dan od dana objave
- „**Vacatio legis**“ – vakacijski rok – razdoblje između objave norme i stupanja na snagu

norme mogu izgubiti primjenjivost *poništenjem* ili *ukidanjem*

1. **poništenje norme** - sudski akt do kojega dolazi ako je norma suprotna višoj normi u formalnoj ili materijalnoj hijerarhiji - djeluje unatrag (kao da nikad nije ni ugledala svjetlo dana)
2. **ukidanje norme** - rezultat je političke odluke zakonodavca
može biti izričito ili prešutno - u pravilu ne djeluje unatrag
- norma se ne može primijeniti prije nego što je objavljena - nakon objavljivanja normi one se ne mogu primijeniti na sporove nastale prije nego što je norma stupila na snagu

6. Pogrešnost

- pogrešna je svaka norma koja nije u skladu s normama o proizvodnji prava kojima se uređuje njezino stvaranje (**formalna pogrešnost**) i/ili nadređenim normama kojima se ograničava njezin mogući sadržaj (**materijalna ili supstancijalna pogrešnost**)
- pojavljuje se: kao posljedica kršenja norme o proizvodnji prava ili posljedica nespojivosti između norme o kojoj je riječ i njoj nadređene norme – i kao uzrok nevaljanosti pogrešne norme

7. Nevaljanost

FORMALNA I MATERIJALNA nevaljanost

- a) **Formalno nevaljana** je svaka norma, odredba ili stavka koje je opterećena formalnom pogrešnošću
- b) **Materijalno nevaljana** -II- opterećena materijalnom ili supstancijalnom pogrešnošću

IZVORNA I NAKNADNA nevaljanost

- a) Izvornom nevaljanošću naziva se nevaljanost koja normu, odredbu ili izvor pogađa od trenutka njezina nastanka—može biti i formalna i materijalna
- b) Naknadnom nevaljanošću naziva se nevaljanost koja normu pogađa od nekog kasnijeg trenutka—može biti samo materijalna
- **tempus regis actum**=Za poduzimanje akta (radnje u postupku) mjerodavno je pravo koje važi u vrijeme njegova poduzimanja

8. Nepostojanje

- nepostojeća je ona norma koja nipošto ne pripada pravnom poretku
 - 1) Nevaljana norma *poništiva* (npr. sklapanje ugovora u zabludi)
 - 2) Nepostojeća norma *ništetna*—postupa se s njima kao da nisu sklopljeni (npr. pravno posao koje je sklopljen pod uporabom sile, *ex lege*)

9. Valjanost i nevaljanost akta, odredbi i normi

- a) **Odredba** - fragment teksta - normativni iskaz koji potječe od nekog tijela normativne vlasti
- b) **Norma** - smisaoni sadržaj, značenje odredbe i rezultat tumačenja teksta
- c) **Normativni akt** - jezično ponašanje koje se sastoji u stvaranju (donošenju) odredbi
 - 1) **formalna valjanost** je svojstvo **normativnog akata** - kršenje normi o proizvodnji dovodi do nevaljanosti akta (pa onda i nevaljanost odredbi vodi do nevaljanosti normi)
 - 2) **materijalna valjanost** je svojstvo **normi** - spojivost i nespojivost (proturječenje, suprotnost) je odnos između značenja (jedna odredba = više normi) proglašenje nevaljanosti jedne od normi izraženih istom odredbom → materijalna valjanost je i svojstvo koje pristaje i odredbi

IV. SASTAVNI DIJELOVI PRAVNOG PORETKA

Norme s obzirom na položaj koji zauzimaju u strukturi pravnog poretka:

- a) **izvorne norme** - čija pripadnost pravnom poretku ne ovisi o postojanju drugih normi
izvedene norme - sve ostale, tj. one čije postojanje počiva na prethodnom postojanju normi
- b) **formulirane** - one koje su izrijekom iskazane ili formulirane u nekoj normativnoj odredbi
neizražene norme - one koje pravnici izvode iz formuliranih normi
- c) **valjane** - svaka norma koja je formalno u skladu i materijalno nije nespojiva s u odnosu na nju formalno i materijalno višim normama i **nevaljane** norme
- d) **norme-pravila i norme-načela** (temeljne norme - daju temelj drugim normama; katkad imaju otvoreno činjenično stanje—imaju neodređeno područje primjene, katkad su otklonjive—podložne su implicitnim iznimkama, katkad su općenite—zahtijevaju dodatne norme kojima ih se specificira i podložne su mnogostrukim konkretizacijama)

V. STRUKTURA PRAVNIH POREDAKA

1. Struktura

- pravni poredak je strukturirani skup normi koje moraju biti međusobno u odnosima
- dva važna odnosa - odnos **utemeljenja** i odnos **hijerarhije**

2. Utemeljenje normi

Jedna norma daje temelj drugoj u dva smisla:

- 1) **dinamika** pravnog poretka i formulirane (izražene) norme - norma o nadležnosti N1 daje dinamički temelj normi N2 kada je N2 stvorilo tijelo normativne vlasti T uspostavljeno normom N1
 - piramidalna struktura prav poredaka - svaka norma nalazi svoj dinamički temelj u nekoj višoj normi sve do vrhovne, neovisne norme lišenje bez ikakvog temelja
- 2) **statika** pravnog poretka i neizražene norme - norma N1 daje statički temelj normi N2 kada je N2 izvediva iz N1 logičkim sredstvima
 - norme koje imaju temelj (statični ili dinamički) su izvedene norme

3. Na vrhu pravnog poretka

- **Kelsen** - pravni poredak ima piramidalnu strukturu - na vrhu piramide stoji „temeljna norma“
- ona nije postavljena, nego „pretpostavljena“
- teza je NEUVJERLJIVA - jer postoje norme bez temelja valjanosti
temeljna se norma smatra beskorisnim udvostručenjem ustava ako prihvatimo da je temeljna norma zapravo prvi ustav, tj. ni valjan ni nevaljan

4. Identitet pravnog poretka

- **temelji se** na identitetu prvog ustava - svaki poredak zadržava identitet sve dok se ne promjene njegove izvorne norme koje pružaju dinamički temelj valjanosti svim ostalim normama
- **gubi** svoj identitet kada se zamjeni njegov ustav - ustav može biti mijenjan bez da poredak izgubi identitet - **problem razlikovanja promjene ustava** (novi ustav) od pukog mijenjanja ustava, tj. razlikovanja ustavotvorne od utemeljene vlasti: *formalističko i supstancijalističko shvaćanje*

5. Hijerarhije normi

1. **Formalna ili strukturna hijerarhija** – između normi o proizvodnji prava (npr. ustavna norma o zakonodavstvu) i u skladu s njima proizvedenih normi (npr. zakonske norme)
2. **Materijalna ili supstancijalna hijerarhija** – prva norma A je materijalno nadređena drugoj normi B, kada je trećom normom C propisani da B ne može valjano proturječiti A.
 - **Meki ustav** je nadređen zakonodavstvu samo u formalnom smislu, dok **kruti** u supstancijalističkom
 - Ove prve 2 vrste oblikuju pojam valjanosti tako da: valjanost zahtjeva sukladnost s formalno višim normama i spojivost s materijalno višim normama
3. **Logička hijerarhija**-između normi i metanormi (npr. između ukidajućih normi i ukinutih normi)
4. **Vrijednosna hijerarhija** – npr. između običnih ustavnih normi i tzv. vrhovnih ustavnih načela
Također između dvaju načela – npr. između slobode tiska i pravo na privatnost

6. Složenost

- 1) **jednostavan pravni poredak** - onaj pravni poredak koji je obilježen jednim tijelom normativne vlasti (npr. vladar) i jednim normativnim izvorom (npr. zakon)
- 2) **razmjerno složen pravni poredak** - onaj pravni poredak koji je obilježen s više hijerarhijski poredanih tijela normativne vlasti (npr. parlament, vlada) od kojih svako ima vlast donositi jednako rangirane izvore različite vrste (npr. zakone i uredbe)
- 3) **vrlo složen pravni poredak** - onaj pravni poredak koji je obilježen s više hijerarhiziranih tijela normativne vlasti i više tijela normativne vlasti istoga ranga (npr. više zakonodavnih organa) od kojih svako ima isključivu nadležnost donositi norme u različitim materijama ili na različitim područjima (npr. Italija, SAD)

pravno uređenje svakog izvora obilježeno je dvjema značajkama:

- a) svakom je izvoru dodijeljen određeni doseg nadležnosti, tj. određen izvor nadležan je uređivati određenu materiju ili izdavati norme na određenom području
- b) svakom je izvoru dodijeljena određeno posebno mjesto u materijalnoj hijerarhiji pravnog poretka, tako da određeni izvor ne može sadržavati norme nespojive s onima izraženima u materijalno nadređenim izvorima

7. Sinkronijska dimenzija i dijakronijska dimenzija

- pravni sustavi su u vremenu promjenljivi skupovi normi ali jedan takav skup zapravo je slijed različitih skupova

pravni poredak se može promatrati s 2 različita gledišta:

- a) **sinkronijsko gledište** - pravni se poredak pojavljuje kao skup normi koji je neizbježno predodređen mijenjati se u vremenu, tj. mijenja se kad god je:
 - 1) neka postojeća norma izbačena iz pravnog poretka (putem ukidanja ili poništenja)
 - 2) neka nova norma uvedena u njega
 - 3) neka postojeća norma u njemu zamijenjena
- b) **dijakronijsko gledište** - pravni se poredak pojavljuje kao dinamičan slijed (statičkih ili dinamičkih) skupova normi tj. normativnih akata

8. Statička dimenzija i dinamička dimenzija

- poredak je dinamične naravi ako su mu kriteriji postojanja i/ili valjanosti isključivo formalni
- svi moderni pravni poredci su istodobno statični i dinamični jer:
- **dinamična narav** - sadrže formalne kriterije valjanosti
- **statična narav**:
 - a) sadrže neki kriterij nevaljanosti koji se odnosi na sadržaj normi (materijalna nevaljanost)
 - b) sadrže neki kriterij valjanosti koji se poziva na sadržaj normi (neizražene norme)

9. Centralizacija i decentralizacija

- **Centraliziran pravni poredak** – poput moderne države - ustanovljava specijalizirane organe (zakonodavne, izvršne i sudske) za proizvodnju i primjenu vlastitih normi
- prema **Kelsenu** to su **države** - centralizirani pravni poredak nužan je uvjet za postojanje države
- **Decentraliziran pravni poredak** – poput međunarodnog pravnog poretka - proizvodnju i primjenu vlastitih normi u cijelosti povjerava adresatima tih normi

10. Dva moguća odnosa između poredaka

- 1) **odnos nadređenosti-podređenosti** - PP1 je podređen PP2 kada "njegova" vrhovna norma istodobno pripada PP2 i obrnuto
PP1 je djelomični, a PP2 potpuni pravni poredak—npr. područni vs. državni poredak
- 2) **odnos međusobne neovisnosti** - kada nisu u odnosu nadređenosti-podređenosti, tj. PP1 je neovisan o PP2 ako njegova vrhovna norma ne pripada PP2 i obrnuto
npr. državnopravni poredak A vs. državnopravni poredak B

VI. SUKOB IZMEĐU NORMI

1. Pojam antinomije

- **ANTINOMIJA** - sukob, nespojivost ili suprotnost između normi (kada jedna norma N1 za činjenično stanje Č daje posljedicu P, a druga norma N2 za isto činjenično stanje Č posljedicu ne-P)
- antinomija postoji kad god je neki slučaj podložen dvama različitim i suprotnim rješenjima
- skup normi bez antinomija naziva se **dosljednim**
- skup normi koji sadrži barem jednu antinomiju naziva se **nedosljednim**

2. Vrste antinomija

- 1) **Antinomije in abstracto** (nužne antinomije) - razmjerno rijetke—postoje kad su dvjema normama nespojive pravne posljedice povezane s apstraktnim činjeničnim stanjima koja se međusobno (potpuno ili djelomično) pojmovno preklapaju
 - one ovise o pojmovnoj strukturi diskursa izvora prava
- 2) **Antinomije in concreto** (kontingentne antinomije) - izrazito česte—postoje kada se zamijeti da se dvjema normama nespojive pravne posljedice povezuju s istim konkretnim činjeničnim stanjem
 - one ovise o činjeničnim okolnostima

Razredi činjeničnih stanja uređeni dvjema antinomijama moгу se preklapati *djelomično* ili *potpuno*:

- 1) **Potpune antinomije** - potpuno preklapanje postoji kada su dvjema normama nespojive posljedice povezane s istim razredom činjeničnog stanja (npr. jednom normom razvod braka se kvalificira zakonitim, a drugom normom nezakonitim)
- 2) **Djelomične antinomije** - može biti dvovrsno:
 - a) **Jednostrano djelomične antinomije** - razred činjeničnih stanja uređen jednom normom u cijelosti sadržan je u razredu činjeničnih stanja uređenom drugom normom (npr. N1 zabranjuje pobačaj, N2 dopušta terapijski pobačaj)
 - b) **Dvostrano djelomične antinomije** - dva razreda činjeničnih stanja presijeću - samo neka od onih uređenih jednom normom poklapaju sa samo nekima od onih nespojivo uređenih 2, normom (npr. N1 zabranjuje lov na veprove i zečeve, N2 dopušta lov na zečeve i lisice)

3. Antinomije i tumačenje

- Normativne odredbe su višeznačne, tj dopuštaju više tumačenja (svakim drugačijim tumačenjem se iz iste odredbe izvodi različita norma) - antinomija je plod tumačenja:
- 1) Može ju se spriječiti ili izbjeći prikladnim majstorijama tumačenja; normativne tekstove može se tumačiti kao da su njima izražene međusobno spojive norme tako da ne dolazi do antinomije
 - prilagođujućim tumačenjem sprječavaju se antinomije između normativnih tekstova
 - 2) Kako se antinomiju posredstvom tumačenja može izbjeći, tako može ju se proizvesti
 - normativne tekstove može se tumačiti kao one koji izražavaju nespojive norme
 - 3) Utvrđenje antinomije pretpostavlja tumačenje—nema antinomije prije tumačenja
 - 4) Antinomije (nastale tumačenjem) otkrivaju problem: ne može biti riješena putem tumačenja zbog:
 - a) **Banalnog razloga** što ako se antinomija pojavi, pojavi samo kada je tumačenje završeno
 - b) **Ne banalnog razloga** što da bi se neka antinomija riješila treba ukloniti jednu od dvije sukobljene norme ili barem jednoj od njih ograničiti doseg

4. Načini rješavanja antinomija – antinomija se javlja u barem u 4 različite okolnosti

1. antinomija između normi **dva istovrsna izvora**

- npr. dva obična zakona, dvije uredbe
- **kriterij kronologije**: kasnija norma ukida raniju - *lex posterior derogat legi priori*

2. antinomija između **normi raznovrsnih izvora**

a) antinomija između normi **dva raznovrsna, različito rangirana izvora**

- pravni ustav i zakon, zakon i uredba
- **kriterij hijerarhije**: viša norma čini nevaljanom nižu - *lex superior derogat legi inferiori*

b) antinomija između normi dva raznovrsna, jednakorangiran izvora različitih dosega nadležnosti, pri čemu jedan zadire u nadležnost drugoga

- npr. zakon i uredba sa zakonskom snagom
- **načelo nadležnosti**: primjena norme iz nadležnog (mjerodavnog) izvora

c) antinomija između normi **dva raznovrsna, jednakorangirana izvora** prava djelomično različitih dosega nadležnosti, pri čemu svaki određuje u svom dosegu

- npr. zakon i uredba sa zakonskom snagom
- **kriterij kronologije**

3. antinomija između državnih normi i normi Europske unije
 - a) antinomija između normi Unije i norme zakonskog ranga (zakonske norme)
 - načelo nadređenosti europskog prava: primjena europske norme
 - zakonska norma se izuzima iz primjene - ali: zakonska norma nije ukinuta ni nevaljana
 - b) antinomija između Unije i ustavne norme
 - primjena europske norme, osim ako nije riječ o vrhovnim ustavnim načelima ili normama kojima se jamče nepovrediva prava - kompromis: države članice zadržavaju marginu diskrecije u uređenju najvažnijih ustavnih pitanja
4. antinomija **između ustavnih načela**
 - neprimjenljivost kriterija hijerarhije, kronologije i specijalnosti
 - **ponderiranje** (odvagivanje) načela – tehnika koju sudovi koriste za rješavanje sukoba
 - uspostavljanje između sukobljenih načela:
 - a) **vrijednosne hijerarhije** - jednoj od normi pridaje se veća vrijednost
vrijednosno viša norma nadvladava nižu → vrijednosno niža norma stavlja se na stranu
 - b) **pomične hijerarhije** - hijerarhija se uspostavlja samo za konkretan slučaj

5. kriterij specijalnosti

- *lex specialis derogat legi generali*
- 1) antinomija između **istorednih normi** koje su u **odnosu pravilo-iznimka**
 - **jednostrano** djelomična antinomija
 - 2 norme su u odnosu pravila i iznimke kada se jednom od njih uređuje neki dani razred činjeničnog stanja
 - Ne smatra se da je jedna od 2 sukobljenih normi nevaljana ili ukinuta, nego ograničen doseg
 - N1(Z trgovine opojnim drogama) – N2(D trgovina kanabisom)
 - N2 ograničava doseg (derogira) N1 → obje norme su i dalje valjane i vrijedeće
 - 2) antinomija između susjednih (istorednih) normi čija se područja primjene djelomično preklapaju
 - **dvostrano** djelomična antinomija
 - i u ovom slučaju jedna od 2 sukobljenih normi nije nevaljana ili ukinuta, nego je ograničen doseg
 - npr N1 (pr. Privatnost – seksualnost Pere Perića) – N2 (sloboda tiska)
 - a) N1 ograničava doseg N2
 - b) N2 ograničava doseg N1

VII. NORME I VRIJEME

1. Vremenske dimenzije normi - 4

1. vrijeme pripadanja (pravnog postojanja)

- počinje kada u trenutku u kojem dotična norma stječe „pravno postojanje“
- **početak** pripadanja: uvođenje u poredak "postavljanjem"
- **svršetak** pripadanja: poništenje
- ukinuta norma poništenjem potpuno gubi svoju primjenljivost, čak u sporovima nastala prije njenog ukinuća

2. vrijeme valjanosti

- **tempus regit actum** - Za poduzimanje akta (radnje u postupku) mjerodavno je pravo koje važi u vrijeme njegova poduzimanja.
- bezvremeno svojstvo
- uz postojanost formalno i materijalno viših normi, svaka je norma ili valjana ili nevaljana
- valjanost se ne stječe ni gubi — ipak: mogućnost izmjene polazišnih normi
- izvorno nevaljana norma ne može postati valjana, ali izvorno valjana norma može izgubiti valjanost - naknadna (ili pridošla) materijalna nevaljanost

3. vrijeme primjenljivosti

- primjenljivost = obveza primjene norme
- **početak** primjenljivosti: "stupanje na snagu" - norme o vacatio legisu
- **svršetak** primjenljivosti: poništenje, retroaktivno ukidanje, nastanak suprotne obveze
- ne i kod neunatragnog ukidanja - dakle: svršetak primjenljivosti ne poklapa se nužno s prestankom bivanja na snazi ili prestankom vrijeđenja

4. vrijeme sposobnosti djelovanja (djelovnosti)

- **doseg djelovnosti** (područje valjanosti, doseg primjene) = skup činjeničnog stanja u nazočnosti kojih norma proizvodi pravne učinke
- **vrijeme djelovnosti** = vremenski odsječak u kojemu treba nastupiti činjenično stanje kako bi uslijedile predviđene pravne posljedice
- **načelo zabrane retroaktivnosti** — vrijeme djelovnosti nije povezano s vremenom primjenljivosti - npr. retroaktivna norma

6. Unatražnodjelujuće (retroaktivne), produljenodjelujuće i prijelazne norme

1. **unatražnodjelujuća norma** - N koja P povezuje s Č koje prethode njezinu stupanju na snagu
2. **produljenodjelujuća norma** - N koja P, čak i nakon što je se ukine, povezuje s Č koje su nastupile prije njezina ukidanja
3. **prijelazna norma:**
 - a) u **funkcionalnom** smislu: koja uređuju prijelaz s jednog uređenja na drugo davanje produljenog ili unatragnog djelovanja
 - b) u **strukturnom** smislu ("privremena"): koja **ab origine** predviđa trenutak prestanka djelovnosti - npr. Zakon o nezastarijevanju k.d. ratnog profiterstva

RETROAKTIVNE NORME — primjeri retroaktivnih normi:

- N kojom se zaprječuje kazna za djela počinjena prije njezina stupanja na snagu
- N kojom se obara već pravomoćna presuda
- N kojom se mijenja uređenje već okončanih odnosa (npr. već ispunjenih ugovora)
- a) N retroaktivna u **slabom smislu**: - kojom se određuje drugačije rješenje sporova nastalih prije njezina stupanja na snagu, a o kojima sud još nije odlučio
- b) N retroaktivna u **jakom smislu**: - kojom se određuje drugačije rješenje sporova nastalih prije njezina stupanja na snagu, a o kojima je sud već odlučio

Peti dio

OD PRAVNOG PORETKA DO DRŽAVE

I. DRŽAVA

1. Prethodni pojmovi

- **Država** – pravni poredak, ali svaki pravni poredak nije država
- **Pravni poredak** – skup „strukturiranih“ normi koje su jedna s drugom u odnosu
U tom smislu bitan odnos – **odnos dinamičkog utemeljenja** (svaka norma koju je donijelo neko tijelo normativne vlasti nalazi svoj dinamički temelj u normi o nadležnosti kojom se ustanovljava)
- dinamički temelj nemaju sve norme pravnog poretka
- **Izvorne** (neovisne) **norme**-njihovo pripadanje pp ne ovisi o prethodnom postojanju drugih normi
- **izvedene** (ovisne) **norme** - sve ostale norme-postojanje ovisi o prethodnom postojanju drugih normi
- 2 odnosa između normi: odnos **međusobne neovisnosti** ili odnos **nadređenosti-podređenosti**
- **Centralizacija** – specijalizirani organi **decentralizacija** – adresati samih normi
- **Društvena učinkovitost (efikasnost) pravnih poredaka** – norma koja se stvarno primjenjuje, učinkovit onaj pp čije norme su uglavnom učinkovite

2. Pojam države

Država je svaki pravni poredak koji :

- 1) Je centraliziran
- 2) Neovisan ili izvoran
- 3) Ima teritorijalno područje sposobnosti djelovanja
- 4) Društveno je učinkovit (efektivan)

3. Vrste državnih pravnih poredaka

Tri gledišta pravnih poredaka:

Način formiranja pravnog poretka	Određen normama o proizvodnji prava—one su materijalni ustav samog poretka	DEMOKRATSKE DRŽAVE norme stvaraju isti subjekti kojima su te norme upućene
		AUTOKRATSKE DRŽAVE norme se stvaraju bez sudjelovanja subjekata kojima su one upućene
Sadržaj pravnog poretka	Skup subjektivnih pravnih položaja ustanovljenih (primarnim i sekundarnim) normama poretka	USTAVNA DRŽAVA ona u kojoj : (a) je politička vlast razdijeljena među više organa, (b) građanima dodijeljena i zajamčena su neka prava slobode
		APSOLUTNA DRŽAVA ona koja ne ispunjava zajedno oba navedena uvjeta
Opseg pravnog poretka	Više ili manje širok - ovisno o broju ponašanja koje uređuje	LIBERALNA DRŽAVA ona u kojoj je pravnim poretkom uređeno samo razmjerno ograničeno područje ljudskog ponašanje (velik broj ponašanja je slobodan)
		TOTALITARNA DRŽAVA ona u kojoj pravnim normama podliježu sva ljudska ponašanja

4. Pravna država

- suprotstavlja se despotskoj i arbitrarnoj vlasti

vrijede 2 temeljna načela:

- 1) **Načelo slobode**—građanima je dopušteno činiti sve ono što im izrijeком nije zabranjeno
- 2) **Načelo zakonitosti**—javnim je vlastima zabranjeno sve ono što im izrijeком nije dopušteno

II. DRŽAVNE „VLASTI“

1. VLAST u dva smisla:

- 1) Vlast **kao državne funkcije**—funkcije su djelatnosti—djelatnosti su razredi akata
- 2) Vlast **kao državni organi** koji izvršavaju različite funkcije

2. Tri temeljne funkcije - koje izvršava vlast (Montesquieu) :

- 1) **ZAKONODAVNI AKTI** - funkcija proizvodnji općih i apstraktnih normi
 - 2) **SUDSKI AKTI** - funkcija utvrđivanja kršenja tih normi—tj. rješavanja sporova koji za predmet imaju kršenje tih normi
 - 3) **UPRAVNO-IZVRŠNI AKTI** - imaju rezidualni karakter; npr. upravni akti (odobrenje, izvlaštenje) i materijalni akti izvršenja (izvršenje sankcija)
- hijerarhije funkcija: sudska i izvršna su logički i pravno podređene zakonodavnoj funkciji
 - izvršna funkcija obuhvaća raznorodne djelatnosti

III. ODVAJANJE I URAVNOTEŽIVANJE VLASTI

1. Dvije tehnike ustrojstva vlasti

- dioba vlasti (*separation of powers*) označava dvije tehnike—odvajanje i uravnoteživanje

2. Odvajanje vlasti

- proizlazi iz spoja dvaju načela:

- 1) **Načelo specijalizacije funkcija** - funkcija je specijalizirana kada je određeni organ izvršava:
 - a) Na isključiv način
 - b) U potpunosti

ona je specijalizirana ako nijednom drugom organu nije pripisana:

- 1) Vlast izvršavanja te funkcije
- 2) Vlast ometanja te funkcije
- 3) Vlast lišavanja sposobnosti djelovanja akata izvršavanja te funkcije

- 2) **Načelo međusobne neovisnosti organa** – kada je svaki organ slobodan od upletanja drugih organa u njegov sastav, funkcioniranje i trajanje

3 stupnja ovisnosti jednog organa o drugog

- 1) Ovisnost najmanja kada A predlaže, izabire i imenuje nositelja B čiji mandat je **neobnovljiv**
- 2) Ovisnost srednja kada A predlaže, izabire i imenuje nositelja B čiji mandat je **obnovljiv**
- 3) Ovisnost najveća kada A predlaže, izabire i imenuje nositelja B čiji mandat A može opozvati prije njegova isteka

3. Uravnotežene vlasti

- Je tehnika ustavnog ustrojstva vlasti –sustav provjera i ravnoteža („*checks and balances*“)
- zahtijeva podijeljenost političke vlasti ali ne i specijalizaciju izvršne i zakonodavne funkcije, te međusobnu neovisnost izvršne i zakonodavne vlasti

model uravnoteživanja vlasti temelji se na Montesquievom nauku—„vlast zaustavlja vlast“;

- 1) Politička vlast treba biti podijeljena među više organa tako da ju nijedan organ ne može izvršavati u cijelosti

- 2) Svaka državna funkcija treba biti raspodijeljena među više organa tako da se radnja svakog organa može spriječiti ili lišiti sposobnosti djelovanja nekog drugog organa
- 3) Različiti organi države trebaju raspolagati vlastima međusobna provjeravanja i utjecanja

4. Oprečne implikacije

1) MODEL ODVAJANJA VLASTI

- izvršna vlast nije politički odgovorna zakonodavnoj
- izvršna vlast ne može raspustiti parlament
- izvršna vlast nema pravo ulaganja veta na zakone
- suci ne mogu nadzirati ustavnost zakona
- suci ne mogu nadzirati zakonitost akata izvršne vlasti

2) MODEL URAVNOTEŽIVANJA VLASTI

- izvršna vlast je politički odgovorna zakonodavnoj
- izvršna vlast može raspustiti parlament te raspisati nove izbore
- izvršna vlast (obično državni poglavar) ima pravo ulaganja veta na zakone
- suci mogu nadzirati ustavnost zakona
- suci mogu nadzirati zakonitost akata izvršne vlasti
- 2 modela unatoč svojim razlikama imaju **zajedničku implikaciju** - specijalizacija sudske funkcije i neovisnost sudova

IV. USTAVNO SUDOVANJE

- podvrgnutost zakonodavca ustavu → ustavna pravna država
- **načelo zakonitosti** - *rule of law* u anglosaksonskoj literaturi, sve javne vlasti podvrgnute zakonu
- **ustavno sudovanje** - ima za učinak odvajanje ustavotvorne vlasti od zakonodavne i održavanje tog odvajanja (nijedan zakonodavac ne može promijeniti ustav)
- Pod izrazom *dioba vlasti* misli se na 2 zasebne tehnike ustavnog ustrojstva vlasti

DIOBA VLASTI U JAKOM SMISLU	Odvajanje vlasti - politička vlast je razdijeljena i podijeljena među više organa; suci se ne mogu upletati u izvršavanje bilo koje druge vlasti - ne mogu ukidati niti odbiti primjenu zakona	Nespojiva s ustavnim sudovanjem
DIOBA VLASTI U SLABOM SMISLU	Uravnoteživanje vlasti - državna je vlast podijeljena među više organa ali se svaka vlast može upletati u izvršavanje ostalih; suci mogu ukinuti ili odbiti primjenu neustavnog zakona	Nipošto nije spojena s ustavnim sudovanjem Zahtijeva neki sustav ustavnog sudovanja

- ustavni sudovi su antidemokratske inst, jer djeluju kao ograničenje vlasti parlamentarne većine
- 1) **Ustavno sudovanje kao sudska funkcija (*pravosuđenje*)** - ustavni sud primjenjuje pravo
 - odluke su obrazložene na temelju ustavnih normi
 - ustavni sud, u pravilu, odlučuje na temelju tuđe inicijative
- 2) **Ustavno sudovanje kao zakonodavna funkcija (*zakonodavstvo*)** - ustavni sud poništavanjem norme mijenja postojeći skup normi
 - u nekim poredcima, ustavni sud dodaje u pravni poredak nove norme (npr. dodajuće i zamjenjujuće odluke)

V. SUVERENOST

SUVERENOST U USTAVNOM PRAVU

- suverenost je vrhovna vlast (*summa potestas*)
- suveren je najviše tijelo pravne vlasti
- suverena je ustavotvorna/utemeljujuća vlast –utemeljujuća vlast je pravno neograničena jer nije dodijeljena pravnim normama nego se izvršava *extra ordinem*

SUVERENOST U MEĐUNARODNOM PRAVU

- suverenost je svojstvo određenih pravnih poredaka (država)→suverenost = državnost
- suverenost je pravna neovisnost jedne države spram drugih država
- u ustavnopravnom poretku postoji jedan suveren, a u međunarodnom pravu poretku mnoštvo suverena

4. Pravna ograničenja suverena

- **Suveren** u pravom smislu riječi ne može biti podvrgnut nikakvim pravnim ograničenjima

1) USTAVNO PRAVO (Kelsen)

- pravna ograničenja ne postoje iz pojmovnih razloga: "suveren" je utemeljujuća vlast (ustav) (kada bi pravna ograničenja postojala onda bi to bila utemeljena vlast)

2) MEĐUNARODNO PRAVO (Kelsen)

- ili su države suverene pa nisu podvrgnute nijednoj normi, ili nisu suverene pa su podvrgnute međunarodnim pravnim normama
 - a) **Države NISU suverene** – te su podvrgnute međunarodnom pravu temelj svakoga od njih se nalazi u normi međunarodnog prava, a ne u njihovim unutarnjopravnim vrhovnim normama načelo efektivnosti ustavima država dodjeljuje valjanost – stoga je ovo gledište neuvjerljivo
 - b) **Države JESU suverene** - države ne podliježu međunarodnom pravu no država je međunarodni pojam - suverenost je nužni uvjet primjenljivosti međunarodnog poretka - i ovo gledište je neuvjerljivo

VI. MEĐUNARODNO PRAVO I DRŽAVNO PRAVO: MONIZAM I DUALIZAM

Državni pravni poredci s međunarodnim pravom:

- 1) **DUALISTI** - Riječ je o različitim pravnim poredcima
- 2) **MONISTI** - Riječ je o jednom makroporetku

3 problema alternative između monizma i dualizma:

1. Općeteorijski problem - različita rješenja utječu na način opisivanja pozitivnog prava
2. Dogmatski ustavnopravni problem - različita rješenja utječu na sadržaj pozitivnog prava
3. Dogmatski međunarodni problem - -II-

Općeteorijski problem - problem konačnog temelja valjanosti državnopravnih poredaka:

- a) **dualistička teza** - zasebni, odvojeni i neovisni poredci – temelj državnopravnih poredaka je u državnim ustavima, a ne u međunarodnom pravu
- b) **monistička teza** - jedan makroporedak – ovisni poredci: jedan poredak je dio drugog poretka dvije inačice: državni monizam i međunarodni monizam

- 1) **državnopravni monizam** - međunarodno pravo je dio državnog prava
 - međunarodno pravo je vanjski dio drž. prava - svaka država ima svoje međunarodno pravo
 - **kritika monizma 1:** "vanjsko pravo" država ima uglavnom istovjetan sadržaj
 - **kritika monizma 2:** međunarodnopravne norme države ne proizvode jednostrano, nego zajedno u međusobnim odnosima
- 2) **međunarodnopravni monizam** - državno pravo je dio međunarodnog prava
 - vrhovna norma državnopravnog poretka je međunarodnopravna norma
 - načelo efektivnosti - međunarodno pravo sadrži "metaustav"
 - **kritika:** načelo efektivnosti nije norma o nadležnosti; ono samo priznaje već postojeću vlast

Dogmatski ustavnopravni problem

- problem neposredne (bez "prilagodbe") primjenljivosti međunarodnopravnih normi?
 - a) dualistička teza → međunarodnopravne norme nisu primjenljive bez "preuzimanja"
 - b) monistička teza → međunarodnopravne norme neposredno su primjenljive
- pozitivnopravni problem: ovisi o tome kako ga rješava pojedini ustav!

Vrste ustava s obzirom na primjenljivost međunarodnopravnih normi :

- 1) **dualističan ustav** - neposredno primjenljivo samo unutarnje pravo
 - međunarodnopravne norme (ugovorne i običajne) primjenljive su samo ako ih se preuzme
 - prešutno dualističan svaki koji ne spominje međunarodno pravo (ne sadrži nikakvu odredbu između unutarnjeg i međunarodnog prava)
- 2) **monističan ustav** - neposredno primjenljive i unutarnje i međunarodnopravne norme (ugovorne i običajne)
- 3) **mješovit ustav** – oni ustavi u kojima se kombinira monistična norma glede međunarodnog općeg prava, s dualističnom normom glede međunarodnog ugovornog prava

unutar "monističkog" i "mješovitog" ustava moguće je:

- a) Međunarodno pravo **nadređeno zakonima** - raniji nespojivi zakoni ukinuti, a kasniji nespojivi zakoni nevaljani
- b) Međunarodno pravo **izjednačeno sa zakonima** - nespojive međunarodnopravne norme ukidaju ranije zakone, a nespojivi zakoni ukidaju ranije međunarodnopravne norme

5. Dualizam i monizam u međunarodnom pravu

- Dogmatski međunarodnopravni problem → problem gledanja međunarodnog prava na državnopravne poretke: je li međunarodno pravo monistično ili dualistično?
- **teza:** dva skupa normi (SN1 i SN2) čine jedan pravni poredak kada se antinomije njihovih normi rješavaju načelima *lex posterior* i *lex superior* - zasebni poredci kada ta načela ne djeluju
 - a) Međunarodno pravo je **monistično** samo ako sadrži normu koja predviđa ukidanje i/ili nevaljanost nespojivih državnopravnih normi s međunarodnopravnim normama
 - b) Međunarodno pravo je **dualistično** ako ne sadrži takvu normu
- **Međunarodno pravo je dualistično!**

Šesti dio **TUMAČENJE (I ŠIRE)**

I. TUMAČENJE: VIŠEZNAČAN IZRAZ

Višeznačnost riječi "tumačenje" - 4 pogleda

1. Prva višeznačajnost: postupak v. proizvod

- a) Kadkada je tumačenjska djelatnost - misaoni postupak
 - Ovu odredbu treba protumačiti prije negoli je se primjeni"
- b) Kadkada je rezultat tumačenjske djelatnosti - "Ova odredba znači x" – diskurs

2. Druga višeznačajnost: apstraktno v. konkretno

- a) tumačenje **in abstracto** (usmjereno na tekst) - utvrđivanje smisaonog sadržaja (tj. norme) bez pozivanja na ijedno konkretno činjenično stanje
 - predmet: potpuni iskaz—npr. što znači "Predsjednik potpisuje vladine uredbe"
- b) tumačenje **in concreto** (usmjereno na činjenice) - podvođenje konkretnog činjeničnog stanja pod područje primjene neke norme . smanjuje ne neodređenost normi
 - **Svrha** - rješavanje konkretnog spora ili kvalifikacija konkretnog činjeničnog stanja
 - **predmet**: predikati (izrazi kojima se označavaju razredi)
 - npr. primjenjuje li se odredba "Ulazak u park vozilima je zabranjen" na tricikl

3. Treća višeznačajnost: spoznaja v. odluka

- a) **spoznajno** (kognitivno) **tumačenje** - utvrđivanje različitih mogućih značenja neke odredbe bez odabira ijednog → O može značiti N1 ili N2
- b) **odlučujuće** (decizivno) **tumačenje** – odabir određenih značenja, odbacujući ostale
 - 1) **standardno** odlučujuće tumačenje - izbor jednog od značenja u okviru mogućih značenja → O znači N1 ili O znači N2
 - 2) **stvaralačko** odlučujuće tumačenje - pripisivanje novog značenja → O znači N3 (N3 ne pripada mogućim značenjima)
- a) **spoznajno tumačenje** - nalik leksičkoj definiciji - znanstvena djelatnost
- b) **odlučujuće tumačenje** - nalik redefiniciji
- c) **stvaralačko tumačenje** - nalik stipulativnoj definiciji - u pravilu se svodi na izvođenje neizraženih normi pseudologičkim sredstvima (zapravo: akt stvaranja prava)
 - spoznajno tumačenje je posve znanstvena djelatnost, dok su odlučujuće i stvaralačko "političke" djelatnosti – može obavljati kako pravni znanstvenik tako i organi primjene

4. Četvrta višeznačajnost: tumačenje v. pravno konstruiranje:

- **pravno konstruiranje** - djelatnost doktrine i sudske prakse
- primjeri: stvaranje vrijednosnih praznina – razvijanje neizraženih normi s ciljem popunjavanja vrijednosnih praznina – stvaranje vrijednosnih hijerarhija između normi— konkretiziranje izraženih načela— odvagivanje između sukobljenih načela

II. DVOSTRUKA NEODREĐENOST PRAVA:

- 1) neodređenost pravnog poretka
- 2) neodređenost pravne norme

1. Višeznačnost normativnih tekstova

- (i.) NT → N1 ili N2? → Predsjednik može imenovati 5 doživotnih senatora.
 - (ii.) NT → N1; da li i N2? → U slučaju da je ishod referenduma protiv ukidanja
 - (iii.) NT → N1; implicira li N1 i N2? → Parlament može izglasovati nepovjerenje Vladi.
 - (iv.) NT → N1; je li N1 "otklonjiva" → Predsjednik može uložiti veto na zakone.
- odgovor: tumačenje in abstracto čime se smanjuje neodređenost pravnog poretka

2. Višeznačnost normativnih tekstova – odredbe i norme

- **odredbe** = formulirani normativni iskazi **norme** = značenja normativnih iskaza
- razlozi nepodudaranja odredbi i normi:
 - 1) normativni iskaz može alternativno izražavati više normi
 - 2) normativni iskaz može istodobno izražavati i/ili implicirati više normi
 - 3) postoje norme bez odredbe (neizražene norme): npr. neizražena opća načela prava

3. Izvori višeznačnosti normativnih normativnih tekstova

- "nedostatci" u formulacijama i iz sljedećih razloga:
 1. osjećaji pravednosti tumača - npr. pravo glasa (državljeni + useljenici?)
 2. raznovrsnost metoda tumačenja - namjera zakonodavca, argument a contrario (paprike-rajčice), argument analogije (a simile), argument razdiobe (gradski-izvangradski prijevoz)
 3. pravna dogmatika - "teorijske" pretpostavke; dogmatske konstrukcije
- npr. pisani ustav implicira načelo da je zakon suprotan ustavu ništetan (Marbury, 1803.), poglavar je "neutralna vlast" (teorija parlamentarne vlade)

4. Nejasnost normi

- neodređenost pravne norme - koja konkretna činjenična stanja pripadaju području primjene norme?
- (ekstenzijska) nejasnost predikata - svojstvo jezika
- predikati imaju spornu ili otvorenu referenciju (open texture)
- teški slučajevi (hard cases): sporna primjenljivost norme - npr. kupoprodaja (na kojoj cijeni postaviti granicu s darovanjem?); dom (odnosi li se i na dvorište i podrum?)
- odgovor: tumačenje in concreto (smanjuje neodređenost normi)

III. PRAVNE PRAZNINE

VRSTE PRAVNIH PRAZNINA:

- 1) normativne praznine
- 2) tehničke praznine
- 3) vrijednosne praznine
- 4) (institucionalne praznine)

1. Normativne praznine

Npr. N1: Ako državljanstvo, onda porez na dohodak

N2: Ako ne prebivalište, onda ne porez na dohodak

N3: Ako nezaposlenost, onda ne porez na dohodak

- Ako zaposleni stranac s prebivalištem, onda ?
- pravno neuređena kombinacija činjeničnih stanja od kojih je svako pojedinačno pravno uređeno
- kombinacija je pravno "relevantna" (ne spada u "pravno prazan prostor")

2. Normativne praznine i tumačenje

- 1) tumačenjem se praznina može proizvesti (na način da se normativne tekstove protumači tako da se praznina pojavi) - praznina nastaje nakon izvršenog tumačenja
- 2) tumačenjem se praznina može spriječiti (izbjeći) (na način da se normativne tekstove protumači tako da se praznina niti ne pojavi) - to je pretumačenje!
- 3) tumačenjem se praznina ne može popuniti - popunjavanje je stvaranje novog prava, a ne tumačenje - to nije tumačenje, nego je pravno konstruiranje!

3. Tehničke praznine

- Postoje u pravnom poretku kada u njemu nedostaje norma čiji je nužni uvjet sposobnosti djelovanja (i/ili društvene učinkovitosti) neke druge norme
- Npr. nekom se normom propisuje periodičko sazivanje nadzornog odbora, ali nije određeno tko ga je ovlašten sazvati, zapovjedna norma bez sankcije itd

4. Vrijednosne praznine

dvije vrste vrijednosnih praznina:

- 1) Neko ČS je uređeno normom, ali to uređenje tumaču čini nezadovoljavajućim

- postoji norma, ali ne "pravedna" norma

- 2) Neko ČS je uređeno normom, ali nije u skladu s materijalno ili vrijednosno višom normom

PRIMJER 1 - N1 uređuje soc osiguranje za radnike - nepravedno za one s ug o radu na određeno vr. pravni poredak sadrži prazninu što se tiče radnika na određeno vrijeme

PRIMJER 2 - porezne olakšice za "trgovačka društva" - velika i mala trg društva bitno različita ustavno načelo jednakosti - nedostaje *razlikovna* norma

PRIMJER 3 - uređenje č.s. "gradski prijevoz" - izvangradski prijevoz?

ustavno načelo jednakosti - nedostaje *ujednačujuća* norma

5. Dogma o potpunosti i pravna država

- **dogma o potpunosti** = svaki pravni poredak je nužno potpun skup pravnih normi
- usko povezano s pravnim liberalizmom - pravni sustav nužno ne sadrži praznine
- **pravna država** = počiva na načelu zakonitosti pravosuđenja kojom se suce obavezuje da svaku svoju odluku utemelje na postojećoj normi

dvije mogućnosti za suca:

- a) U pravnoj državi sudac ima obvezu riješiti svaki pravni spor - zabrana uskraćivanja pravosuđa
- b) U pravnoj državi vrijedi načelo diobe vlasti – sudsku praksu isključuje s popisa izvora prava, stvaranje prava monopol zakonodavnih organa - predvidljivost sudskih odluka
- načelo zabrane unatragdjelovanja zakona!
- dakle: u pravnoj se državi suca priječi da izbjegne odluku i da odluči stvarajući novu normu

6. *Opća isključujuća norma*

- Svi pravni sustavi nužno sadrže zatvarajuću normu; načelo slobode (opća isključujuća norma)
 - OIN je kontingentna (sadržana samo u nekim liberalnim poredcima)
 - OIN ponekad vrijedi samo za određeno područje prava (npr. kazneno pravo)
 - OIN ne vrijedi u području javnog prava (načelo zakonitosti)
- **Nullum crimen, nulla poena, sine lege** - nitko ne može odgovarati za kazneno djelo, ako učinjeno djelo nije u zakonu predviđeno kao kazneno
- dakle: moguća su pravno nekvalificirana ponašanja (to su praznine)

IV. PRAVNO KONSTRUIRANJE:

- Širok raspon doktrinarnih (i sudskih) radnji: stvaranje vrijednosnih praznina i hijerarhija, rješavanje antinomija, razvijanje neizraženih normi, konkretiziranje načela

1. *Neizražene norme*

- norme koje nije izričito formulirala nijedna normativna vlast
- izvedena je iz jedne ili više normi putem rasuđivanja
- **rasuđivanje** – slijed iskaza gdje barem jedan iskaz služi kao zaključak, dok drugi ga podupiru
- jedan ili više izraženih normi čine **premise** rasuđivanja, dok neizražena norma čini njegov **zaključak**

3 vrste rasuđivanja - 3 vrste neizraženih normi + neizražena načela (nagađanje o **ratio legis**)

- 1) izvođenje iz valjanog (deduktivnog) logičkog rasuđivanja - "čuva istinitost" (ništa ne dodaje premisama; iz njih samo izvodi ono što je u njima već implicirano) sve premise su izražene norme

Npr. N1: Pravo glasa imaju punoljetne osobe.

N2: Osobe s navršenih 18 godina su punoljetne.

NN3: Pravo glasa imaju osobe s navršenih 18 godina.

- Logički su implicirane u izraženim normama - plod posve spoznajne intelektualne djelatnosti

- 2) izvođenje iz logički nevaljanog rasuđivanja

premise: izražene norme + logički nevaljani argumenti (npr. a contrario, a simili)

Npr. N1: Državljeni imaju pravo glasa.

ARG: a contrario

NN2: Stranci nemaju pravo glasa i ono se na njih (npr. zakonom) ne može proširiti.

Npr. N1: Porezna olakšica za "velika trgovačka društva".

ARG: a simili

NN2: Porezna olakšica i za mala trgovačka društva.

- U oba slučaja (argument a contrario i a simili) pravnom poretku dodana nova neizražena norma

3) izvođenje iz spoja izraženih normi i dogmatskih pretpostavki ili samo iz dogmatskih pretpostavki

- srž doktrinarnog (dogmatskog) rada

Npr. N1: Zabranjena izmjena republikanskog oblika države.

DP: Nema republike bez demokracije.

NN2: Zabranjena izmjena demokratskog oblika države

Npr. N1: Europski sud uzima da europsko pravo i pravna država čine jedan pravni poredak

N2: europske norme nadređene unutarnjim normama država članica

Iz toga: Sud zaključuje da je državno zakonodavstvo nevaljano

3. *Konkretizacija načela*

primjena ustavnih načela:

a) ustavni sudovi – ocjenjivanje ustavnosti zakona

b) redovni sudovi – popunjavanje (najčešće vrijednosnih) praznina

- u oba slučaja ne mogu primijeniti bez prethodne konkretizacije

- **konkretizirati** – upotrijebiti kao premisu u rasuđivanju - zaključak: novo (neizraženo) pravilo

Npr. UN: Pravo na zdravlje je nepovredivo.

Logička implikacija: Šteta na zdravlju predstavlja protupravnu (neimovinsku) štetu.

NN: Protupravne neimovinske štete treba nadoknaditi.

V. **PRAVNA ZNANOST**

U literaturi se spominje za označavanje dviju razmjerno različitih stvari

a) **znanost u pravom smislu riječi**

- opisujući (spoznajni) diskurs o pravu— ne-vrednujući (vrijednosno neutralni) diskurs

b) **doktrina ili dogmatika** - diskurs pravnika kakav on jest - **doktrina**” = ukupnost pisanih djela i/ili mišljenja akademskih pravnika → ne ograničava se na opisivanje prava!

1. *Pravna znanost u pravnom smislu riječi*

- pravo v. pravna znanost

- oboje su diskursi (sljedovi iskaza formuliranih prirodnim jezikom)

pravo = skup normi

pravna znanost = skup sudova o normama

- logički različiti diskursi

1. propisujući (pravo) i opisujući (pr. znanost)

2. jezik-predmet (pravo) i metajezik (pr. znanost)

- **problem:** sudovi pravne znanosti često su formulirani kao norme (ponavljanje poput jeke)

3. *Dva shvaćanja pravne znanosti*

1) **normativizam** - opisivanje prava = opisivanje pravnih normi (“pravo u knjigama” - law in books)

- **pravo** = skup općih pravnih normi koje su proizveli zakonodavci u materijalnom smislu

2) **realizam** opisivanje prava = opisivanje sudskih odluka (“pravo u praksi” - law on action)

- ono koje se stvarno primjenjuje

- **pravo** = ono što odlučuje suci (organi primjene) u konkretnim slučajevima

1. **Normativističko shvaćanje** pravne znanosti - opisivanje prava = "opisivanje **normi**"
 - a) opisivanje značenjskog sadržaja normativnih tekstova ("prava u knjigama")
 - normativni tekstovi su višeznačni
 - veliki interes za popisivanje različitih mogućih značenja normativnog teksta
 - ne govori ništa o "vrijedećem" pravu niti o neizraženim normama
 - b) opisivanje "vrijedećeg tumačenja", tj. načini kako se normativni tekstovi stvarno primjenjuju
 - značenje nije uvijek određeno – nisu svi sporovi glede tumačenja vječni
 - značenje nije potpuno određeno – značenje normativnog teksta može se razviti u 2 dijela: nesporno jezgreno područje i sporno rubno područje
2. **Realističko shvaćanje** pravne znanosti - "opisivanje **činjenica**" - predviđanje (predikcija)
 - a) opisivanje sudske prakse (skupa sudskih odluka)
 - suci ne sude jednoobrazno na temelju postojećih normi (psihološke pobude, etičko-politička usmjerenja, osjećaji pravednosti sudaca) - izvođenje pravilnosti, a ne pravila
 - b) opisivanje "vrijedećeg tumačenja" - opisivanje normi koje suci stvarno primjenjuju
 - opisivanje normi (rationes decidendi) koje se primjenjuju sudskim odlukama

4. **Doktrina**

- nije istinski znanstvena djelatnost - ne sastoji se isključivo u opisivanju vrijedećeg prava
- **srž doktrinarnog rada** = oblikovanje prava na 2 različita i povezana načina
 - a) određivanje, značenjskog sadržaja normativnih tekstova - odlučujuće i/ili stvaralačko tumačenje
 - b) razvijanjem (konstruiranjem) novih normi
- doktrina je dio samoga prava

VI. **PRIMJENA PRAVA**

1. **Primjena**

- Izraz **primjena prava** – označava uporabu pravnih materijala, tj. odredbi, izraženih i neizraženih normi za argumentiranje ili opravdanje pravne odluke

3 gore navedena razlikovanja:

- 1) Razlikovanje odredbi (iskazi diskursa izvora prava) i normi (značenja koje su odredbama pripisana)
- 2) Razlikovanje izraženih i neizraženih normi
- 3) Razlikovanje pravila (norma za zatvorenim antecendentom) i načela (norma za otvorenim antec.)

razlikovanje primjenu odredbi, primjenu pravila i primjenu načela

- 1) **primjena odredbi** - tumačenje, pripisivanje značenja, radi izvođenja norme
 - Odredba O izražava normu N
- 2) **primjena pravila** - uporaba pravila kao premise u deduktivnom rasuđivanju čiji je zaključak pojedinačan i konkretan propis - Npr. Ubojice treba kazniti. Petar je ubojica. Stoga Petra treba kazniti
- 3) **primjena načela** - konkretiziranje; uporaba načela kao premise u rasuđivanju čiji je zaključak neizraženo pravilo
 - Pravo na zdravlje je nepovredivo. Šteta na zdravlju predstavlja protupravnu štetu. Stoga takvu štetu treba naknaditi

2. Pravosuđenje, zakonitosti, obrazloženje

- sudska odluka je pojedinačan i konkretan propis
značajke pravosuđenja u modernim pravnim poredcima:
 - a) podvrgnutost suca zakonu (obveza primjene prava)
 - b) obrazlaganje sudskih odluka (izlaganje razloga)
- sudske odluke moraju biti: obrazložene -argumentiranje, opravdane na temelju postojećih prav normi
- **odluka se smatra utemeljenom** ako je logički izvedena iz spoja opće norme i činjeničnog suda koji opisuje okolnosti slučaja
- **neutemeljena odluka** bez obrazloženja ili "utemeljena" na sučevu hiru, osjećajima pravednosti...

3. Sudačko rasuđivanje

dvije razine sudačkog rasuđivanja - "unutarnje" i "vanjsko" opravdanje

- 1) **"unutarnje opravdanje"** - deduktivno rasuđivanje: **primjena pravila**
 - a) Prva premisa – rezultat odlučujućeg tumačenja in abstracto - [pravilo]: Ubojice treba kazniti.
 - b) Druga premisa – opisuje se činjenice slučaja -[činjenični sud]: Petar je Pavlu prerezao grkljan.
 - c) Traća premisa – in concreto - [podvedeći iskaz]: Prerezati grkljan je ubojstvo.
 - d) Zaključak - [pojedinačan i konkretan propis]: Petra treba kazniti.
- 2) **„vanjsko opravdanje“** - skup nededuktivno rasuđivanje: opravdavanje premisa unutarnjeg opravdanja **primjena odredbi i načela:**
 - a) opravdanje normativnih premisa:
 - 1) tumačenjski argumenti - opravdavanje odabranog tumačenja odredbe
 - 2) konstruktivni argumenti - opravdavanje pravnog konstruiranja (npr. postojanje vrijednosne praznine, rješavanje antinomija, stvaranje vrijednosnih hijerarhija između normi)
 - b) opravdanje činjeničnih premisa
 - dokazno rasuđivanje ("pripovjedna suvislost")
 - empirijska opažanja i nagađanja o uzročnim vezama između događaja

VII. PRAVOSUĐENJE I ZAKONODAVSTVO

2 različita načina razlikovanja sudskih i zakonodavnih akata

1. **Materijalno** razlikovanje zakonodavstva i pravosuđenja
 - a) Zakon - normativni (opći i apstraktan) sadržaj
Presuda -pojedinačan i konkretan sadržaj
 - b) Zakon - rezultat akata volje
Presuda -rezultat dvostrukog utvrđivanja ili spoznaje (utvrđivanje zakona i činjenica)
 - c) Zakonodavstvo - s obzirom na cilj slobodna djelatnost
Pravosuđenje - djelatnost nužno usmjerena na primjenu zakona
 - d) Zakonodavstvo - izvorna, prvotna djelatnost neovisna o drugima
Pravosuđenje - djelatnost strukturno podređena zakonodavstvu

zakonodavstvo = stvaranje novih normi

pravosuđenje = spoznaja i primjena postojećih normi

- ne može se zaključiti da se zakonodavni organi uvijek i samo bave zakonodavstvom, niti da se

sudski organi uvijek i samo bave pravosuđenjem – tako definira barem 4 razloga:

- a) zakoni-odluke (pojedinačni zakoni; formalni zakoni)
- b) zakonodavac primjenjuje ustavne norme
- c) tumačenje je i vrednujuća i odlučujuća djelatnost
- d) suci popunjavaju pravne praznine koja je moguća popuniti proizvodnjom nove norme

2. **Formalno** razlikovanje zakonodavstva i pravosuđenja

a) **oblik organa:**

zakon - potječe od kolegijalnog predstavničkog organa, članove se bira na izborima

presuda - potječe od kolegijalnog ili pojedinačnog birokratskog organa – bira putem natječaja

b) **postupak stvaranja:** *zakon* - rezultat postupka odlučivanja koji samostalno pokreće

zakonodavni organ i koji je obilježen pravilom većine i javnosti sjednica

presuda - rezultat parničnog postupka koji pokreću adresati odluke, o kojoj se odlučuje u tajnosti

c) **struktura dokumenata:** *zakon* - normativni akt

presuda - obrazložen akt

d) **pravno uređenje akta:** *zakon* - erga omnes

presuda - inter partes

4. **Dioba zakonodavstva i pravosuđenja**

2 različite nadležnosti rezervata

1) **ZAKONODAVNI REZERVAT** - zakonodavna funkcija rezervirana za zakonodavni organ

Sucima zabranjeno "donositi zakone" u smislu:

1. sudske odluke djeluju inter partes i ne mogu biti obvezujući presedani
2. zabrana izricanja "arbitrarnih" presuda
3. zabrana formuliranja novih normi ne svedivih na postojeće zakone
4. zabrana neprimjene neustavnih zakona → različiti ustavotvorni poredci

Pravila prema kojem je sucima zabranjeno odbiti primjenu neustavnih zakona:

1. pravni poredci s mekim ustavom (UK) – navedeno pravilo je u potpunosti obvezujuće
2. pravni poredci s krutim ustavom u kojem nadzor ustavnosti zakona izvršava politički pravni organ - navedeno pravilo je obvezujuće
3. pravni poredci s krutim ustavom u kojem nadzor ustavnosti zakona na difuzan način izvršavaju svi suci - navedeno pravilo ne vrijedi (SAD)
4. pravni poredci s krutim ustavom u kojem nadzor ustavnosti zakona u centraliziranom obliku izvršava poseban ustavni sud - navedeno pravilo ne vrijedi (Ita, Špa, Njem)

2) **PRAVOSUDNI REZERVAT** - sudska funkcija rezervirana za sudske organe

zakonodavac ne smije "zadirati" u sudsku funkciju:

- (i) zabrana pojedinačnih zakona povezana s načelom jednakosti
 - takva zabrana vjerojatno ne postoji ni u jednom ustavnopravnom poretku
 - zakon se obično shvaća u formalnom smislu
- (ii) zabrana zakona kojima se utječe na već pokrenute ili okončane sudske sporove
 - načelo res iudicata (presuđena stvar) rijetko je propisano ustavom
 - načelo zabrane retroaktivnih (unatražnodjelujućih) zakona u mnogim ustavnopravnim poredcima vrijedi samo za područje kaznenog prava
 - tumačenje nije sudska funkcija, a autentično tumačenje je zakonodavna funkcija